

Respecto al alcance de la competencia del Defensor del Pueblo en el orden nacional, en cuanto si ésta alcanza a las administraciones provinciales o incluso a las comunales, entendemos que no, dado su carácter de órgano perteneciente a la estructura orgánica federal.

Pero en razón de que las cuestiones a considerar se relacionen con violaciones a derechos fundamentales (los contenidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional) cometidos por autoridades locales, puede intervenir para efectivizar el principio de supremacía constitucional (arts. 5º y 31 de la Ley Mayor).

Es así que sin hesitación alguna puede afirmarse que el campo espacial de este actor institucional engloba a todo el territorio nacional.

Es de considerar la eventual y posible presencia de inconvenientes prácticos que ello puede conllevar atento tratarse de un órgano personalizado con asiento físico en la Capital Federal. Esta circunstancia implica las consiguientes dificultades para materializar el contacto directo con los problemas a resolver.

Una posible solución sería establecer delegaciones provinciales que permitirían tener un contacto más directo con las problemáticas existentes en todo el país; ello sería una forma de "federalización del ombudsman".

9. RESPONSABILIDAD

El nacimiento del constitucionalismo a fines del siglo XVIII, que reconoce en la eclosión histórica que implicaron la Revolución Francesa y la declaración de los Derechos del Hombre, con una relación diferente entre el Estado y los habitantes, al establecer limitaciones en el ejercicio del poder, reconociendo la existencia de derechos inalienables que deben ser respetados y no pueden desconocerse por resultar superiores y preexistentes, presta sustento al Estado de Derecho, que implica responsabilizar al Estado por sus acciones y/u omisiones.

Ello así es de resaltar que no existe función pública sin responsabilidad del agente; esta regla es de aplicación al Defensor del Pueblo, a quien se le atribuye responsabilidad institucional y social.

El reproche de la responsabilidad institucional trae como consecuencia su remoción, la social el repudio de los ciudadanos en razón que ésta se sustenta en la aprobación de sus actos.

Desde otro orden, a fin de determinar su responsabilidad institucional, es necesario evaluar el marco de competencia adjudicado al órgano, es decir, la misma se sustenta en la función investigativa, mediadora, innovadora y garantista en defensa de la Constitución.

Asimismo responde por la teoría general de responsabilidad civil por los daños que cause a terceros, lo que implica su obligación de reparación y su responsabilidad penal. Para analizar su conducta debe probarse la concurrencia de todos los requisitos exigidos por la doctrina para el nacimiento del daño causado, como ser la relación causal, la antijuridicidad y el factor de atribución de responsabilidad.

Específicamente, la actividad de este actor institucional debe analizarse dentro del juego armónico de los arts. 1109 y 1112 del Código Civil, los cuales son conducentes para determinar que el factor de atribución de su responsabilidad por los hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones es subjetivo por tratarse de un hecho que le es propio e imputable por dolo o culpa, para lo cual es necesario comprobar que es el actor del perjuicio causado (*imputatio facti*) y además es culpable material del mismo (*imputatio iuris*).

La responsabilidad institucional es amplia en razón de la infinidad de las funciones que se le asignan por la Constitución y que se encuentran consignadas en la normativa de aplicación, cuyo cumplimiento resulta ilusorio habida cuenta de la falta de infraestructura necesaria para lograr los objetivos propuestos, influyendo además, la situación económica reinante en el país, es decir, que atento la realidad circundante siempre existirá en el cumplimiento del conjunto de deberes y obligaciones a su cargo un amplio espectro de omisiones por los cuales no puede responder.

En razón de las afirmaciones precedentes es de entender que la negligencia que se le imputa en el ejercicio de su función debe ser notoria y estar referida al incumplimiento de las obligaciones expresas y concretas que la norma le impone en su carácter de agente administrativo.

La normativa de aplicación dispone que su responsabilidad surja de las causales enumeradas en el art. 10 incs. d) y e) de la normativa vigente, destacando además, que para lo previsto en el inc. a) (renuncia) si abandona el cargo sin que la misma le fuere aceptada y esta actitud daña el servicio que debe prestar incurre en el delito previsto en el art. 252 del Cód. Penal.

El análisis de lo dispuesto en el art. 10 permite aseverar que para determinar su responsabilidad por sus actos u omisiones no basta con probar la simple omisión en sus funciones institucionales, sino que no se desempeñe conformes las disposiciones contenidas en el art. 512 del Cód. Civil.

Para el caso de reproche por notorias negligencias en los deberes del cargo según el contenido del inc. e) primera parte del artículo citado, el reproche por notoria negligencia en los deberes del cargo requiere que para incurrir en responsabilidad su actitud debe ser —insistimos— notoria, es decir, conocida por todos y en términos jurídicos debe categorizarse de grave, manifiesta e indubitable.

En relación a los daños a terceros que causare en el ejercicio de sus funciones su responsabilidad emerge conforme lo dispuesto por el art. 1112 del Cód. Civil que nos remite a las normas generales de responsabilidad aplican-

121

dose además lo dispuesto por el art. 902 del citado código que prevé una mayor obligación de obrar con prudencia y pleno conocimiento de los casos.

La responsabilidad funcional se fundamenta sustancialmente en la notoria negligencia con la cual implementa su conducta las que pueden enunciarse en los siguientes supuestos:

- a) Negarse a recibir una queja.
- b) No tramitar una queja recibida en tiempo y forma.
- c) No derivar la queja a la autoridad competente, cuando no recaiga dentro del ámbito de su competencia o se formule fuera del término establecido.
- d) Cuando diera curso a las quejas que expresamente debe rechazar por mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial, o porque respecto de la cuestión planteada se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial (conf. art. 21, ley 24.284).
- e) Cuando rechazara quejas sin fundamento (puede rechazarlas cuando su tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona).
- f) Cuando no interrumpiera el curso de la queja, suspendiendo su intervención, al tomar conocimiento de la iniciación de recurso administrativo o acción judicial por parte de la persona interesada.
- g) Cuando no comunicara al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiese dado al organismo o funcionario implicados, excepto que éstas sean consideradas de carácter reservado o declaradas secretas.
- h) No poner en conocimiento de la Auditoría General de la Nación, en los casos que corresponda, los resultados de sus investigaciones sobre los organismos sometidos a su control.
- i) No promover la investigación sumaria a que diera origen la queja, absteniéndose de solicitar los informes y de realizar las inspecciones y verificaciones que correspondieran.
- j) No dar traslado al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones penales correspondientes, de los antecedentes de quien impida u obstaculice las investigaciones a su cargo.
- k) No comunicar de inmediato al Procurador General de la Nación, los hechos presumiblemente delictivos de acción pública de los cuales tome conocimiento.
- l) Emitir resoluciones modificando, sustituyendo o dejando sin efecto decisiones administrativas o de cualquier otro ente que estuviera alcanzado por la órbita de su competencia.

- m) No presentar su informe anual, antes del 31 de mayo de cada año.
- n) No incluir en el informe anual a los funcionarios o entidades que, sin emitir una justificación adecuada, no hicieron lugar a las recomendaciones formuladas por el defensor.
- ñ) No dar cuenta en el informe del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado.
- o) Hacer constar en el informe los datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento de investigación.
- p) No incluir en el informe la rendición de cuentas del presupuesto de la institución en el período que corresponda.

En cuanto a la responsabilidad social la misma por la naturaleza de sus funciones es más amplia que la de otros funcionarios y se sustenta en la vinculación directa de la actividad que desarrolla con la protección y defensa de los derechos e intereses del pueblo.

10. CONCLUSIONES

Podemos consignar claramente que el Defensor del Pueblo es un órgano independiente y autónomo, elegido por el Congreso, dedicado a la defensa y protección de los derechos de las personas. Tiene la facultad de investigar con el objetivo de esclarecer actos que afecten los intereses difusos o colectivos.

Hemos recordado antecedentes históricos que nos llevan a comprender la función y la importancia de este órgano para todo Estado. Cómo pasó de ser una figura exclusiva de los países escandinavos, para formar parte de más de una treintena de estados, incluyendo la Argentina la cual incorporó la figura en la reforma constitucional de 1994.

En particular, el Defensor del Pueblo en nuestro país es un ente relativamente nuevo que presenta diferentes características, funciones y también limitaciones, todas expuestas en el art. 86 de la Constitución Nacional y en las leyes 24.284 y 24.379.

La tarea será exitosa en la medida que se le asigne a la institución los recursos económicos necesarios y del reconocimiento que se le adjudique como colaborador de la administración.

Es necesario que el Defensor del Pueblo actúe con transparencia, utilice la persuasión y mediación en su gestión funcional, con responsabilidad subjetiva en su función que se fundamenta sustancialmente en la grosera negli-

Respecto al alcance de la competencia del Defensor del Pueblo en el orden nacional, en cuanto si ésta alcanza a las administraciones provinciales o incluso a las comunales, entendemos que no, dado su carácter de órgano perteneciente a la estructura orgánica federal.

Pero en razón de que las cuestiones a considerar se relacionen con violaciones a derechos fundamentales (los contenidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional) cometidos por autoridades locales, puede intervenir para efectivizar el principio de supremacía constitucional (arts. 5º y 31 de la Ley Mayor).

Es así que sin hesitación alguna puede afirmarse que el campo espacial de este actor institucional engloba a todo el territorio nacional.

Es de considerar la eventual y posible presencia de inconvenientes prácticos que ello puede conllevar atento tratarse de un órgano personalizado con asiento físico en la Capital Federal. Esta circunstancia implica las consiguientes dificultades para materializar el contacto directo con los problemas a resolver.

Una posible solución sería establecer delegaciones provinciales que permitirían tener un contacto más directo con las problemáticas existentes en todo el país; ello sería una forma de "federalización del ombudsman".

9. RESPONSABILIDAD

El nacimiento del constitucionalismo a fines del siglo XVIII, que reconoce en la eclosión histórica que implicaron la Revolución Francesa y la declaración de los Derechos del Hombre, con una relación diferente entre el Estado y los habitantes, al establecer limitaciones en el ejercicio del poder, reconociendo la existencia de derechos inalienables que deben ser respetados y no pueden desconocerse por resultar superiores y preexistentes, presta sustento al Estado de Derecho, que implica responsabilizar al Estado por sus acciones y/u omisiones.

Ello así es de resaltar que no existe función pública sin responsabilidad del agente; esta regla es de aplicación al Defensor del Pueblo, a quien se le atribuye responsabilidad institucional y social.

El reproche de la responsabilidad institucional trae como consecuencia su remoción, la social el repudio de los ciudadanos en razón que ésta se sustenta en la aprobación de sus actos.

Desde otro orden, a fin de determinar su responsabilidad institucional, es necesario evaluar el marco de competencia adjudicado al órgano, es decir, la misma se sustenta en la función investigativa, mediadora, innovadora y garantista en defensa de la Constitución.

Asimismo responde por la teoría general de responsabilidad civil por los daños que cause a terceros, lo que implica su obligación de reparación y su responsabilidad penal. Para analizar su conducta debe probarse la concurrencia de todos los requisitos exigidos por la doctrina para el nacimiento del daño causado, como ser la relación causal, la antijuridicidad y el factor de atribución de responsabilidad.

Específicamente, la actividad de este actor institucional debe analizarse dentro del juego armónico de los arts. 1109 y 1112 del Código Civil, los cuales son conducentes para determinar que el factor de atribución de su responsabilidad por los hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones es subjetivo por tratarse de un hecho que le es propio e imputable por dolo o culpa, para lo cual es necesario comprobar que es el actor del perjuicio causado (*imputatio facti*) y además es culpable material del mismo (*imputatio iuris*).

La responsabilidad institucional es amplia en razón de la infinidad de las funciones que se le asignan por la Constitución y que se encuentran consignadas en la normativa de aplicación, cuyo cumplimiento resulta ilusorio habida cuenta de la falta de infraestructura necesaria para lograr los objetivos propuestos, influyendo además, la situación económica reinante en el país, es decir, que atento la realidad circundante siempre existirá en el cumplimiento del conjunto de deberes y obligaciones a su cargo un amplio espectro de omisiones por los cuales no puede responder.

En razón de las afirmaciones precedentes es de entender que la negligencia que se le imputa en el ejercicio de su función debe ser notoria y estar referida al incumplimiento de las obligaciones expresas y concretas que la norma le impone en su carácter de agente administrativo.

La normativa de aplicación dispone que su responsabilidad surja de las causales enumeradas en el art. 10 incs. d) y e) de la normativa vigente, destacando además, que para lo previsto en el inc. a) (renuncia) si abandona el cargo sin que la misma le fuere aceptada y esta actitud daña el servicio que debe prestar incurrirá en el delito previsto en el art. 252 del Cód. Penal.

El análisis de lo dispuesto en el art. 10 permite aseverar que para determinar su responsabilidad por sus actos u omisiones no basta con probar la simple omisión en sus funciones institucionales, sino que no se desempeñe conformes las disposiciones contenidas en el art. 512 del Cód. Civil.

Para el caso de reproche por notorias negligencia en los deberes del cargo según el contenido del inc. e) primera parte del artículo citado, el reproche por notoria negligencia en los deberes del cargo requiere que para incurrir en responsabilidad su actitud debe ser —insistimos— notoria, es decir, conocida por todos y en términos jurídicos debe categorizarse de grave, manifiesta e indubitable.

En relación a los daños a terceros que causare en el ejercicio de sus funciones su responsabilidad emerge conforme lo dispuesto por el art. 1112 del Cód. Civil que nos remite a las normas generales de responsabilidad aplicán-

dose además lo dispuesto por el art. 902 del citado código que prevé una mayor obligación de obrar con prudencia y pleno conocimiento de los casos.

La responsabilidad funcional se fundamenta sustancialmente en la notoria negligencia con la cual implementa su conducta las que pueden enunciarse en los siguientes supuestos:

- a) Negarse a recibir una queja.
- b) No tramitar una queja recibida en tiempo y forma.
- c) No derivar la queja a la autoridad competente, cuando no recaiga dentro del ámbito de su competencia o se formule fuera del término establecido.
- d) Cuando diera curso a las quejas que expresamente debe rechazar por mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial, o porque respecto de la cuestión planteada se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial (conf. art. 21, ley 24.284).
- e) Cuando rechazara quejas sin fundamento (puede rechazarlas cuando su tramitación irroque perjuicio al legítimo derecho de tercera persona).
- f) Cuando no interrumpiera el curso de la queja, suspendiendo su intervención, al tomar conocimiento de la iniciación de recurso administrativo o acción judicial por parte de la persona interesada.
- g) Cuando no comunicara al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiese dado al organismo o funcionario implicados, excepto que éstas sean consideradas de carácter reservado o declaradas secretas.
- h) No poner en conocimiento de la Auditoría General de la Nación, en los casos que corresponda, los resultados de sus investigaciones sobre los organismos sometidos a su control.
- i) No promover la investigación sumaria a que diera origen la queja, absteniéndose de solicitar los informes y de realizar las inspecciones y verificaciones que correspondieran.
- j) No dar traslado al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones penales correspondientes, de los antecedentes de quien impida u obstaculice las investigaciones a su cargo.
- k) No comunicar de inmediato al Procurador General de la Nación, los hechos presumiblemente delictivos de acción pública de los cuales tome conocimiento.
- l) Emitir resoluciones modificando, sustituyendo o dejando sin efecto decisiones administrativas o de cualquier otro ente que estuviera alcanzado por la órbita de su competencia.

- m) No presentar su informe anual, antes del 31 de mayo de cada año.
- n) No incluir en el informe anual a los funcionarios o entidades que, sin emitir una justificación adecuada, no hicieron lugar a las recomendaciones formuladas por el defensor.
- ñ) No dar cuenta en el informe del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado.
- o) Hacer constar en el informe los datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento de investigación.
- p) No incluir en el informe la rendición de cuentas del presupuesto de la institución en el período que corresponda.

En cuanto a la responsabilidad social la misma por la naturaleza de sus funciones es más amplia que la de otros funcionarios y se sustenta en la vinculación directa de la actividad que desarrolla con la protección y defensa de los derechos e intereses del pueblo.

10. CONCLUSIONES

Podemos consignar claramente que el Defensor del Pueblo es un órgano independiente y autónomo, elegido por el Congreso, dedicado a la defensa y protección de los derechos de las personas. Tiene la facultad de investigar con el objetivo de esclarecer actos que afecten los intereses difusos o colectivos.

Hemos recordado antecedentes históricos que nos llevan a comprender la función y la importancia de este órgano para todo Estado. Cómo pasó de ser una figura exclusiva de los países escandinavos, para formar parte de más de una treintena de estados, incluyendo la Argentina la cual incorporó la figura en la reforma constitucional de 1994.

En particular, el Defensor del Pueblo en nuestro país es un ente relativamente nuevo que presenta diferentes características, funciones y también limitaciones, todas expuestas en el art. 86 de la Constitución Nacional y en las leyes 24.284 y 24.379.

La tarea será exitosa en la medida que se le asigne a la institución los recursos económicos necesarios y del reconocimiento que se le adjudique como colaborador de la administración.

Es necesario que el Defensor del Pueblo actúe con transparencia, utilice la persuasión y mediación en su gestión funcional, con responsabilidad subjetiva en su función que se fundamenta sustancialmente en la grosera negli-

122

gencia con la cual implementa su conducta y no se desempeñe conforme las disposiciones contenidas en el art. 512 del Cód. Civil y dentro del juego armónico de los arts. 1109 y 1112 del Código citado.

CAPITULO II.1

EL PODER EJECUTIVO

SUMARIO: 1. Naturaleza unipersonal del órgano. — 2. Su dinámica operativa: a) Introducción. b) Elección. c) Funciones. d) Las Jefaturas presidenciales. — 3. Atribuciones del Poder Ejecutivo. a) Las relaciones internacionales. b) El poder reglamentario. c) Participación en el proceso legislativo. d) Poder de nombramiento. e) Indulto y conmutación de penas. f) Poderes militares. — 4. Cese y acefalía.

1. NATURALEZA UNIPERSONAL DEL ÓRGANO

El análisis de la institución presidencial en nuestro país se halla condicionado por datos provenientes de la historia y de la praxis política, amén de lo que discipline el texto constitucional propiamente dicho. La evolución de este cargo ha respondido en líneas generales a las mismas características que la institución ofreció en el resto de América Latina (1). Así, a la considerable masa de atribuciones que le reconoció la Constitución de 1853/60, se sumaron prácticas que, oriundas en el período colonial, implicaron una fuerte concentración de potestades en manos del titular del Ejecutivo.

La norma constitucional es diáfana al expresar el art. 87: "*El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de 'presidente de la Nación Argentina'*". Claramente se trata de un oficio unipersonal (2), y no de un órgano colegiado. En este orden de ideas, es importante recordar que los ministros *dependen* del órgano ejecutivo, pero que éste está compuesto por una sola persona: el Presidente.

(1) La visión norteamericana primigenia está dada por la estricta separación entre el Ejecutivo y el Congreso. V. SARTORI, GIOVANNI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Bolonia, 1996, p. 100. Empero, "las numerosas imitaciones de la forma de Gobierno norteamericana en el centro y sur de América Latina, en Asia (Corea del Sur y Filipinas) y en África (Namibia y Nigeria) han dado vida a un régimen netamente desequilibrado a favor del poder ejecutivo y de Jefe del Estado y por tanto *degenerativo respecto del modelo originario definido como presidencialista*". V. LÓPEZ GARRIDO, DIEGO; MASSÓ GARROTE, MARCOS FCO., y PEGORARO, LUCIO (Directores), *Nuevo Derecho Constitucional Comparado*, Valencia, 2000, p. 237 (énfasis agregado).

(2) V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada*, Buenos Aires, 2005, p. 797.

Cabe computar que esta magistratura define a la forma de gobierno argentina, que es republicana (art.1º) y presidencialista. Bien señaló Karl Loewenstein en su oportunidad que lo que caracteriza al presidencialismo es la *interdependencia por coordinación*, es decir, una prolija delimitación y deslinde del haz de competencias de cada órgano del Poder público. El art. 99 es un ejemplo en donde se enumeran las atribuciones del Presidente (tal como lo hace el art. 75 respecto del Congreso, y el art.116 en relación con la justicia federal).

Juan Bautista Alberdi propugnaba en su obra "Bases" un Ejecutivo fuerte y vigoroso, sometido a la Constitución, capaz de emprender las obras de progreso que necesitaban estas tierras. El citado art. 87 actual de nuestra Constitución es una virtual réplica del art. 77 de su Proyecto constitucional.

2. SU DINÁMICA OPERATIVA

a) Introducción

El problema radica no en el cargo presidencial en sí mismo, como en la hipertrofia que por tradición y por desvío de poder ha tenido en la experiencia política argentina y latinoamericana en general, a lo que se debe agregar la suma de atribuciones fruto a lo largo del s. XX de una mayor intervención estatal en la vida económica y social, lo que ha llevado a muchos autores a hablar de "hiperpresidencialismo" e incluso a propiciar la adopción de esquemas híbridos (3) o directamente parlamentaristas (4). La propia reforma constitucional de 1994 pareció en la teoría orientarse hacia la atenuación del régimen presidencialista, cuando en el plano de las conductas esta última década testimonia todo lo contrario (5).

b) Elección

Desde esa revisión, la elección presidencial se realiza mediante sufragio directo (art. 94), reemplazándose el modelo hasta entonces vigente y que permitía, al igual que acontece en los Estados Unidos, un mejor equilibrio entre las provincias integrantes de la federación (6).

(3) Algunos evocan el semi-presidencialismo francés. V. NEUSTADT, RICHARD N., *Presidential Power*, New York, 1980, p. 204. Para un estudio sobre los orígenes de esta matriz gubernativa, ver FAVOREU, LOUIS; MAUS, DIDIER y PARODI, JEAN-LUC, *La escritura del Poder Ejecutivo en la Constitución francesa de 1958*, México, 2006.

(4) V. GORDILLO, AGUSTÍN, "La constitucionalidad formal del eterno retorno...", Res Publica Argentina 2006-2, p. 59 y sigtes.

(5) Hemos expresado en CARNOTA, WALTER F., y MARANIELLO, PATRICIO A., *Constitución de la Nación Argentina*, Buenos Aires, 2007, p. 18, que el presidencialismo argentino se ha fortalecido a partir de 1994 desde lo formal (con la posibilidad de reelección inmediata y por el sistema de voto directo, en detrimento del federalismo) y desde lo material (con la incorporación de la delegación legislativa, los DNU y la promulgación parcial de leyes).

(6) Ibídem.

Se prevé una segunda vuelta electoral (art. 96), con dos excepciones.

En efecto, una primera alternativa la suministra el art. 97 constitucional: "Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiera obtenida más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación".

La segunda posibilidad está brindada por el art. 98: "Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación".

Recordemos que el mandato presidencial es de cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección (arts. 90 y 91).

c) Funciones

Sobre el punto, expresa Germán Bidart Campos: "¿Cuál es la función del poder ejecutivo? ¿Cómo se compone su competencia? El adjetivo 'ejecutivo' podría dar la pauta de que es un mero 'ejecutor', que se limita a aplicar las decisiones proporcionadas por los otros órganos del poder. Y nada más lejos actualmente de la verdad y de la realidad. El poder ejecutivo tiene el liderazgo del poder político, y es el motor primitivo y principal de la dinámica estatal. Su actividad suele descomponerse en dos rubros: a) la actividad política en su sentido más puro, o actividad gubernamental, y b) la actividad administrativa. Ambas son actividades vitales, continuas y permanentes. Ambas importan conducir y dirigir realmente la empresa estatal, y accionar sin paréntesis el poder político" (7).

Desde la perspectiva de su función estrictamente política, no caben dudas de que el Ejecutivo despliega una acción de liderazgo o caudillaje que se ha visto acrecentada a lo largo del s. XX en casi todos los sistemas políticos del mundo que cuentan con el oficio presidencial en su estructura de gobierno (8). El presidente es, en términos del art. 99 inc.1, "jefe supremo de la Nación". Lícito es interrogarse la compatibilidad de este enunciado con aquel del art.29 que veda el otorgamiento de "sumisiones o supremacías" (9). Como sea, en su correcta interpretación, implica ser el Jefe de Estado y de gobierno.

(7) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, Buenos Aires, 1993, t. II, p. 272. Ya decía González que "El Departamento Ejecutivo es... el gobierno eficiente de la sociedad, porque es el que ejerce constantemente acción práctica sobre ella". V. GONZÁLEZ, FLORENTINO, *Lecciones de Derecho Constitucional*, París, s/f, p. 303.

(8) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, Buenos Aires, 2000, t. II, p. 41; ídem, CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 90.

(9) Lamentablemente, se ha visto como contemporáneamente "el reglamentarismo constitucional se dirige más a cuestiones técnicas (urbanísticas, ambientales, energéticas, demo-

Aclaremos que, a diferencia de la jerga que se utiliza en los sistemas parlamentaristas, el "gobierno" no sólo lo integra el departamento ejecutivo. El Congreso e incluso la Corte Suprema ejercen también funciones gubernativas desde sus respectivas esferas de competencia.

La función administrativa (10) significa, después de la reforma constitucional de 1994, que el Presidente es el "responsable político de la administración general del país", en términos también del ya citado art. 99 inc. 1. Más allá de la aparición de la novedosa figura del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100), que "ejerce la administración general" (id., inc. 1), la última palabra en esta materia la tiene la presidencia, quien titulariza la función aunque la ejerza el Jefe de Gabinete. Además, el Presidente "concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación" (art. 99, inc. 6).

d) Las jefaturas presidenciales

Clásicamente, antes de 1994, se hablaba de la existencia de cuatro jefaturas en cabeza del Presidente. Así, se distinguía:

- 1) la jefatura del Estado;
- 2) la jefatura de la administración pública;
- 3) la jefatura local e inmediata de la Capital Federal;
- 4) la comandancia en jefe de las fuerzas armadas (11).

A partir de la revisión constitucional, el Presidente continúa siendo el Jefe de Estado, a lo que la reforma al inc. 1 del art. 99 agregó expresamente que es el Jefe de gobierno y responsable político de la administración. Como vimos, el Presidente continúa siendo el titular último de la Administración Pública, más allá que su ejercicio se halla encomendado al Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo estipula el art. 100, inc. 1.

Queda en claro, en virtud del art. 99, inc. 12, que el Presidente es "el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación". En cambio, no retuvo la jefatura de la Capital Federal, en atención al proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129, C.N.).

gráficas, fiscales, procesales, por ejemplo) que a aspectos relacionados con las garantías del orden democrático-constitucional". V. VALADÉS, DIEGO, *El Control del Poder*, Buenos Aires, 2005, p. 100.

(10) "En el caso del poder Ejecutivo, que tiene la ventaja de una decisión centralizada y en gran medida única, se ve limitada por la actividad de la burocracia, que tiene intereses propios que pueden no coincidir con los del gobierno". V. SOLA, JUAN V., *Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2006, p. 657.

(11) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Tratado Elemental...*, obra y tomo citados, p. 302. Desde un ángulo sociológico-político, bien se ha dicho que "el propio diseño institucional requiere que el presidente despliegue muy distintas caras, facetas y papeles (institucionales, políticos y sociales)". Ver SERRAFERO, MARIO D., "El rompecabezas presidencial. Algunas paradojas", en BERCHOLZ, JORGE (Director), *El Sistema Político e Institucional en la Argentina*, Buenos Aires, 2006, p. 286.

3. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Gregorio Badeni ha clasificado a estas atribuciones, agrupándolas en las siguientes categorías:

- 1) administrativas;
- 2) reglamentarias;
- 3) colegislativas;
- 4) legislativas;
- 5) garantías institucionales;
- 6) nombramiento de funcionarios;
- 7) indulto y conmutación de penas;
- 8) relaciones exteriores;
- 9) militares (12).

El grueso de las mismas se localiza en el art. 99, sin perjuicio de poder figurar en otras reglas del plexo de base.

a) Las relaciones internacionales

Un área típica de competencia del órgano ejecutivo es la referida al manejo de las relaciones con los demás Estados y con los organismos internacionales. En toda estructura federal, dicha conducción está reservada por vía de principio al gobierno central, y dentro de sus órganos, al ejecutivo, consecuente con la "jefatura del Estado" que el art. 99 inc. 1 imputa a la presidencia. Así, el Jefe de Estado ostenta la representación internacional del mismo.

En esa sintonía, dice el art. 99 inc. 11, que el Presidente:

"Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules".

De la norma claramente se derivan dos potestades puntuales:

- 1) la negociación de tratados y concordatos;
- 2) recibe a los embajadores extranjeros. Correlativamente a esta última atribución, el Presidente " nombra y remueve a los embajadores, mi-

(12) V. BADENI, GREGORIO, *Tratado de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2004, p. 1247.

nistros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado" (id., inc. 7).

b) El poder reglamentario

Aquí es donde se patentizan las facultades administrativas de la presidencia. No existe con esta contundencia en el sistema norteamericano. Prescribe el inc. 2 del art. 99 lo siguiente:

"Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".

Es así que el Ejecutivo dicta los llamados "decretos reglamentarios", "reglamentos" o "actos administrativos de alcance general".

Los mismos se clasifican en:

- a) *Reglamentos autónomos*: son aquellos que el Poder Ejecutivo dicta en ejercicio de sus propias atribuciones, con el objeto de ordenar sus facultades específicas. No requieren delegación o habilitación alguna del Congreso. Por el contrario, los mismos se ubican en la zona de reserva de la Administración. Ejemplos: los reglamentos que diseñan los recursos administrativos, o que proveen al empleo público.
- b) *Reglamentos de ejecución* (art. 99, inc. 2° C.N.): también llamados decretos reglamentarios, son aquellos previstos en la norma constitucional aludida, que autorizan al Poder Ejecutivo a pormenorizar y especificar normas dentro del marco de una determinada ley del Congreso, a los efectos de conferirles la necesaria operatividad. Aquí se evidencia la subordinación de la administración a la legislación, en tanto y en cuanto los mismos no pueden evadirse de las pautas delineadas por el Congreso.
- c) *Reglamentos de necesidad y urgencia*: Son los que se producen en los términos y condiciones del art. 99 inc. 3 C.N.
- d) *Reglamentos delegados*: Son los que se emiten previa habilitación del órgano Congreso, en los términos del art. 76 y del art. 100 inc. 12 C.N.

c) Participación en el proceso legislativo

Algunos autores hacen referencia a la función "colegisladora" del Ejecutivo. Nosotros preferimos conservar la denominación de "participación" que tiene el Presidente en el desarrollo legislativo, que es la que otorga el art. 99 inc. 3 "in limine".

- a) El Presidente tiene derecho de *iniciativa* en materia de proyectos de ley, conforme lo estipula el art. 77;
- b) El Presidente puede aprobar total (arts. 78 y 80) o parcialmente (art. 80) un proyecto de ley ("promulgación");

- c) Hace publicar las leyes (art. 99, inc. 3 cit.);
- d) También tiene derecho de veto, en los términos del art. 83;
- e) No puede emitir *bajo pena de nulidad* disposiciones de carácter legislativo (art. 99, inc. 3, segundo párrafo), con las importantísimas (y peligrosas) excepciones de los decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3, tercer y cuarto párrafos), la delegación legislativa (art. 76) y promulgación parcial de normas (art. 80 de la C.N.).

d) Poder de nombramiento

El Presidente de la Nación goza de una serie de prerrogativas en materia de nombramientos de funcionarios públicos:

- a) En el caso de los diplomáticos (embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios), los designa y remueve con acuerdo del Senado (art. 99, inc. 7).
- b) Los jueces de la Corte Suprema son nombrados con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública especial. Nombra también a los demás jueces de los tribunales federales (de primera y de segunda instancia) en base a una *terna* que le suministra el Consejo de la Magistratura. Se requiere también acuerdo senatorial en sesión pública (art. 99 inc. 4). Esta atribución ha sufrido una interesante "auto-restricción" en virtud de lo pautado por los decretos 222 y 588 del año 2003, donde somete a los futuros jueces a las observaciones del pueblo.
- c) Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado, y por sí sólo en el campo de batalla (art. 99 inc. 13, ver "infra").
- d) Por sí sólo nombra y remueve al Jefe de Gabinete de Ministros, a los demás ministros, a los oficiales de su secretaría, a los agentes consulares y a los demás empleados cuyo procedimiento de designación no se encuentre reglado por la Constitución (art. 99, inc. 7, "in fine").

e) Indulto y conmutación de penas

Se trata de facultades presidenciales conferidas por el art. 99 inc. 5. Son instituciones que se derivan de la "clemencia" que el derecho regio ponía en cabeza del monarca. Como rémora de éstos, perviven hoy en día en manos del Ejecutivo, más allá de su difícil coordinación conceptual con el principio de la división de funciones del poder.

El *indulto* implica un perdón de la sanción de un delito impuesta por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, aunque la jurisprudencia admitió su procedencia aún frente a procesos judiciales en curso. La *conmutación* significa un cambio por una pena menor, es decir, una reducción. En ambas situaciones, no se borran los demás efectos que pudo irrogar la sentencia condenatoria.

126

Sólo son susceptibles de este beneficio las condenas producidas en el ámbito de la jurisdicción federal, previo informe del respectivo tribunal. No es admisible en los casos de juicio político, ni ante los delitos constitucionales tipificados por el art. 36, C.N. Tampoco es una potestad oponible ante delitos de lesa humanidad, con arreglo a lo resuelto por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Mazzeo, Julio Lilo" (sentencia del 13 de julio de 2007).

f) Poderes militares

Cuatro son las normas del art. 99 que se refieren a esta cuestión. Todas ellas denotan la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, representado por la presidencia.

El Presidente:

Inc. 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.

Inc. 13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla.

Inc. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.

Inc. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.

4. CESE Y ACEFALÍA

De conformidad con lo estipulado por el art. 88, el Presidente cesa (además de la finalización de su mandato de cuatro años) por muerte, renuncia o destitución (ver, asimismo, arts. 53 y 59 en materia de juicio político). En esos supuestos de acefalía, como en la enfermedad o ausencia temporarias, el Presidente es reemplazado por el Vicepresidente.

Claro está que estas contingencias, como asimismo la inhabilidad, pueden sobrevenir sobre ambos gobernantes. Es así que se produce la situación de *acefalía, tanto del Presidente como del Vicepresidente*, derivándose a una ley del Congreso a fin de que estipule qué funcionario desempeñará la jefatura del Estado.

En virtud de ello, el Congreso dictó la ley 20.972 y su modificatoria, la ley 25.716, más allá de las lagunas evidenciadas en materia de acefalía del cargo vicepresidencial, hipótesis recurrente en la historia institucional argentina (13).

(13) V. ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, *Instituciones de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2004, p. 133.

CAPÍTULO II.2

JEFE DE GABINETE

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Antecedentes. — 3. Atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros. — 4. Atribuciones y funciones dadas por la Ley de Ministerios. — 5. Atenuación del presidencialismo. — 6. Diferentes corrientes doctrinarias. a) Acercamiento a la figura del Primer Ministro. b) Atenuación del Jefe de Gabinete. — 7. Administración y gobierno. — 8. Diferentes tesis funcionales. a) Tesis de la relación-supervisión. b) Tesis de la relación-jerarquía. — 9. A modo de reflexión.

1. INTRODUCCIÓN

En los modelos parlamentarios la figura del Primer Ministro ocupa un lugar fundamental en el estamento político, mientras que nuestro país que sigue netamente un sistema presidencialista, con la reforma de 1994 en el art. 100, ha incorporado la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.

Muchos son los argumentos sostenidos por los diversos juristas y doctrinarios acerca del por qué de la incorporación de esta nueva figura en nuestro ordenamiento jurídico.

En el presente capítulo también se desarrollará un estudio de los antecedentes que impulsaron su incorporación dentro de la Constitución Nacional y —por ende— dentro del orden jurídico argentino, con el necesario interrogante: ¿en nuestro país existe un Jefe de Gabinete fuerte o débil, atenuador o reforzador del poder presidencial?

2. ANTECEDENTES

Como ya hemos dicho en el capítulo anterior, en la Constitución que nos regía el Presidente de la Nación detentaba cinco jefaturas. Así el primer magistrado era jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe de la administración general del país, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe inmediato y local de la Capital Federal (1).

(1) CASSAGNE, JUAN CARLOS, "En torno al jefe de gabinete", LA LEY, del 5/12/1994.

"La combinación de elementos provenientes del presidencialismo y del parlamentarismo, formas clásicas de gobierno de la democracia para la configuración de una forma mixta o como un medio de atenuación de los modelos puros, ha sido un método bastante utilizado en las constituciones a lo largo del presente siglo. Ello ha sido así en Francia, Portugal, Finlandia, Uruguay, Perú, Austria, entre muchas otras. En ellos siempre subyace la adopción de mecanismos que se insertan dentro del principio de separación de poderes, evitando los desequilibrios y asegurando un esquema adecuado de frenos y contrapesos.

La nueva institución [en referencia al Jefe de Gabinete] tiene por finalidad la descentralización de funciones en el interior del ejecutivo y el control del accionar del primer magistrado, de otro modo no hubiera sido concebido en aras de atenuar al presidencialismo" (2).

3. ATRIBUCIONES DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

El nuevo artículo 100 de nuestra Ley Fundamental enumera las atribuciones del instituto del Jefe de Gabinete de Ministros incorporado luego de la reforma de la Constitución de 1994.

"El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:

1. *Ejercer la administración general del país.*
2. *Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.*
3. *Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente.*
4. *Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.*

(2) SABSAY, *El Presidencialismo en América Latina y en la Argentina*, en: www.conhist.org/

5. *Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.*
6. *Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.*
7. *Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto nacional.*
8. *Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.*
9. *Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.*
10. *Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.*
11. *Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.*
12. *Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.*
13. *Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.*

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio".

Con respecto a la función de "ejercer la administración general del país" que el art. 100, inc. 1º le confía al Jefe de Gabinete, ello pareciera indicar que se trata de un jefe de gobierno, pero esto no es así, pues el art. 99 le concede dicha jefatura, de manera expresa al Presidente de la Nación. Además en la misma disposición se aclara que este último es "el responsable político de la administración del país" (inc. 1º). Se trataría, entonces, de un colaborador más del Presidente, quien es el que regula el ámbito de su competencia y el protagonismo que deberá llevar a cabo. Por lo tanto, se acercaría más a la figura de un ministro-coordinador que al jefe de un gabinete de ministros.

Del mismo modo, dentro de la reforma constitucional de 1994, se hace referencia a las potestades presidenciales, de nombramiento y remoción del Jefe de Gabinete, pues la moción de censura del Congreso es de tan difícil ejercicio que de hecho resultará prácticamente imposible que alguna vez se concrete en la práctica.

De conformidad con lo expresado en los arts. 100 y 101, el Jefe de Gabinete es responsable políticamente ante el Congreso, responsabilidad que se hace efectiva a través de la interpelación de que puede ser objeto y posterior voto positivo de censura. En los sistemas parlamentarios el planteamiento de la censura requiere de la voluntad de un pequeño número de legisladores, en tanto su efectivización resultará del voto de la mayoría de los miembros presentes en la votación. En el semipresidencialismo los requisitos son mayores en la medida que la presentación de la censura requiere de un número más elevado de legisladores que en el parlamentarismo. Inclusive en sistemas presidencialistas que contemplan la censura ministerial no aparece una exigencia tan severa.

Sin embargo sus funciones son el resultado de la supervisión, subordinación o delegación de los poderes que el Presidente tenga a bien derivarle. Más bien se tratará de una suerte de coordinador de gabinete y de nexo con el Poder Legislativo. Modalidades que lo acercan a las características que ha tenido el cargo de Secretario General de la Presidencia. Por otra parte, la potestad reglamentaria que se le concede (art. 100, inc. 2º), no debe confundirse con la función de aplicación de las leyes que conserva el Presidente de la Nación con carácter exclusivo (art. 99, inc. 2º). En realidad, se trata del dictado de resoluciones —como también les cabe a los restantes ministros— para poner en ejercicio las funciones que le son atribuidas en el art. 100. Pero, de ningún modo toma a su cargo acto alguno que comprenda la función reglamentaria del poder ejecutivo, que de manera categórica retiene el Presidente. Tampoco en materia de nombramientos recibe una porción importante de poder, pues a los ministros los designa el Presidente, quien, a su vez, conserva sus atribuciones en lo atinente a magistrados, oficiales superiores y diplomáticos (art. 99, incs. 4, 7 y 13). Por último, es notable el rol de supervisión que sobre todos los actos del Jefe de gabinete ejerce el Presidente, en algunos casos ello es así de manera explícita, como por ejemplo en el inc. 10 del artículo 99 o resulta de la potestad que este último posee de solicitarle los "informes que crea convenientes" (art. 99, inc. 17).

Por todo ello, la atenuación del sistema presidencialista mediante la implementación de la Jefatura de Gabinete fue un propósito de la reforma (ley 24.309, art. 2º del Núcleo de Coincidencias Básicas, apartado A) que no se logró plasmar. Ello por tres razones principales: a) El Jefe de Gabinete es nombrado y removido por el presidente (art. 99 inc. 7); b) Ejerce la administración general del país, las facultades que le delegue el presidente (art. 100 incs. 1, 2, y 3) y refrenda, como cualquier ministro, los decretos reglamentarios de las leyes (art. 100 inc. 8); c) El presidente sigue siendo el Jefe Supremo de la Nación, del gobierno, responsable político de la administración del país y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (art. 99 incs. 1 y 12). Es decir que el presidente continúa siendo lo que era: el Jefe y el responsable político de la conducción del país ejerciendo, el Jefe de Gabinete, prácticamente en todos los órdenes, las atribuciones que su mandante le delegue.

Hasta que no sea modificada la constitución, la figura del Jefe de Gabinete es débil, si tenemos en cuenta que virtualmente carece de atribuciones

propias, lo que impide considerar que se obtuvo una atenuación del régimen presidencialista (3).

4. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DADAS POR LA LEY DE MINISTERIOS

El art. 16 de la Ley de Ministerios (según modificaciones del decreto 684/2003) establece que: *"Son atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, las establecidas en la Constitución Nacional. En consecuencia le corresponde:*

1. *Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la legislación vigente;*
2. *Ejercer la administración general del país y asistir al Presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración;*
3. *Ejercer las atribuciones de administración que le delegue el Presidente de la Nación, respecto de los poderes propios de éste;*
4. *Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar;*
5. *Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia;*
6. *Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional con ambas Cámaras del Congreso de la Nación, sus Comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Nacional procurando la mayor fluidez en dichas relaciones y el más pronto trámite de los mensajes del Presidente de la Nación que promuevan la iniciativa legislativa;*
7. *Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, relativos a la marcha del Gobierno, y los demás que le fueren requeridos por las Cámaras del Congreso;*
8. *Dictar Decisiones Administrativas, referidas a los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y aquellas que le delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del Ministro Secretario que corresponda en razón de la materia;*
9. *Entender en la definición de las políticas de recursos humanos y en el seguimiento y evaluación de su aplicación, que aseguren el desarrollo y funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa;*

(3) Ello tanto en la constitución formal cuanto en la material.

129

10. Entender en el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional, procurando optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con que cuenta;
11. Dirigir y supervisar el accionar del Cuerpo de Administradores Gubernamentales;
12. Aprobar las estructuras organizativas de la jurisdicción, ministerios y organismos descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo;
13. Presentar al Congreso de la Nación, junto con los Ministros Secretarios, la memoria anual detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los Ministerios;
14. Hacer recaudar las rentas de la Nación;
15. Intervenir en la elaboración y control de ejecución de la Ley de Presupuesto, como así también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos, sin perjuicio de la responsabilidad primaria del Ministro Secretario del área y de la supervisión que al Presidente de la Nación compete en la materia;
16. Requerir de los Ministros Secretarios, Secretarios y demás funcionarios de la Administración Pública Nacional la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de los artículos 100, incisos 10 y 11, y 101 de la Constitución Nacional, la que deberá producirse dentro del plazo que a tal efecto establezca;
17. Asistir al Presidente de la Nación en el análisis de los mensajes que promueven la iniciativa legislativa, en particular los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto que deberán ser tratados en Acuerdo de Gabinete, y de los proyectos de leyes sancionados por el Congreso Nacional;
18. Asistir al Presidente de la Nación en el dictado de instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación y de los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a extraordinarias del Congreso de la Nación;
19. Coordinar y controlar la ejecución de las delegaciones autorizadas a los Ministros Secretarios;
20. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso de sus atribuciones;
21. Coordinar y controlar las prioridades y relaciones interjurisdiccionales vinculadas con la gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito;
22. Coordinar el seguimiento de la relación fiscal entre la Nación y las Provincias;
23. Entender en la evaluación y priorización del gasto, efectuando el diagnóstico y seguimiento permanente de sus efectos sobre las condiciones de vida de la población;

24. Entender en la distribución de las rentas nacionales, según la asignación de Presupuesto aprobada por el Congreso, y en su ejecución;
25. Intervenir en la aplicación de la política salarial del sector público, con participación de los Ministerios y organismos que correspondan;
26. Intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización;
27. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de suministros del Estado;
28. Entender en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social;
29. Entender en la difusión de la actividad del Poder Ejecutivo Nacional, como así también la difusión de los actos del Estado Nacional a fin de proyectar la imagen del país en el ámbito interno y externo;
30. Administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista;
31. Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad deportiva en todas sus formas".

Mediante esta extensa enumeración de atribuciones parecería que el Jefe de Gabinete realmente ostenta gran poder en el ejercicio de su rol. Sin embargo, como ya se ha expuesto, la nueva figura permanece "en tela de juicio" por estar supeditada a la voluntad del Presidente en cuanto a su nombramiento y remoción (art. 99, inc. 7°).

Por otra parte, habría que analizar si realmente todas estas atribuciones podrían ser otorgadas al Jefe de Gabinete, pues parecería que existe una contradicción aparente entre las delegaciones por medio de esta ley y la disposición que la Carta Magna establece en cuanto a que el Jefe de Gabinete "no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio" (art. 100, inc. 13).

5. DIFERENTES CORRIENTES DOCTRINARIAS

a) Acercamiento a la figura del primer ministro

Parte de la doctrina sostiene que la creación del instituto del Jefe de Gabinete de Ministros ha ocasionado un acercamiento al régimen parlamentario. Por este motivo, algunos autores han asemejado la figura del Jefe de Gabinete a la del Primer Ministro del parlamentarismo o de alguna forma mixta de gobierno.

Por ejemplo, "el rasgo característico del sistema inglés es que los miembros del gabinete, así como su primer ministro son electos por el Parlamento. Este gabinete podría ser denominado como un comité o comisión del Parlamento. Sin embargo, el poder legislativo, por influjo de la tradición y de las experiencias exitosas, puede disolver al Parlamento que lo ha nombrado y llamar a otro; detenta, asimismo, un veto suspensivo" (4).

En el sistema parlamentario existe una estrecha relación entre el Poder Ejecutivo, el Gabinete y el Parlamento, de modo tal que los poderes Legislativo y Ejecutivo se encuentran completamente fusionados. Conforme a lo dicho, "el gabinete requiere de la confianza del Parlamento para perdurar, esto se traduce en una notable diferencia con el sistema presidencialista estadounidense, en el cual el órgano ejecutivo no puede ser destituido normalmente por el Congreso, sino a través del *impeachment*" (5).

En cambio, en el presidencialismo norteamericano la mayor cuota de poder pasa por el Presidente, quien elige a los miembros del gabinete. En este caso, el Poder Ejecutivo no forma parte del Legislativo. Sin embargo, a pesar de la concentración de importantes facultades en manos del Poder Ejecutivo, el Presidente no es en absoluto *todopoderoso*.

Aunque el gabinete norteamericano ha sido ignorado por la Constitución, en la mayoría de los casos, los miembros del gabinete pertenecen al partido político del Presidente (6), y de este modo actúan como sus asesores incondicionales.

En los sistemas parlamentaristas y semipresidencialistas el Primer Ministro es una institución independiente de la voluntad del jefe de Estado, cuya permanencia está ligada a la decisión del Parlamento, quien brinda o retira la confianza en función de su composición política interna.

Esta manifestación de perseguir la flexibilización de los mecanismos de control del Legislativo sobre el Ejecutivo en aras de hacer frente a las crisis, con facultades si bien excepcionales de real y posible utilización, habla de la esencia de todo sistema de relaciones en una forma de gobierno que aún manteniendo su esencia presidencialista busca notas parlamentarias como contrapeso (7).

De este modo, la figura del Jefe de Gabinete de Ministros lejos estaría de asemejarse a la del Primer Ministro presente en los sistemas parlamentaristas y semipresidencialistas.

(4) BARRAZA, J. I. y OTRA, *El Jefe de Gabinete de Ministros*, Buenos Aires, 1999, p. 39.

(5) *Ibidem*.

(6) Es necesario aclarar la presencia de un sistema bipartidista en los Estados Unidos, compuesto por el Partido Republicano y el Partido Demócrata.

(7) SABSAY, D. A. y ONAINDIA, J. M., *La Constitución de los Argentinos*, Buenos Aires, 1995.

b) Atenuación del presidencialismo

Según Cassagne (8), la atenuación del poder se observa en tres aspectos:

- la prohibición de que el presidente ejerza facultades delegadas por el congreso, con las excepciones habilitantes del art. 76;
- la competencia del congreso para remover al jefe de gabinete en las condiciones establecidas por el art. 101; y
- la prohibición de que el presidente dicte decretos de necesidad y urgencia, salvo en los casos del art. 99, inc. 3°.

En el caso particular de la interacción de las competencias presidenciales y la inserción del Jefe de Gabinete, el mismo Cassagne (9) refuerza la distinción. Por un lado, el Presidente de la República retiene la jefatura del estado y la del gobierno (art. 99, inc. 1°), pero la jefatura de la administración ha recibido un deslinde bastante ambiguo, puesto que el presidente es responsable *político* de la administración general del país (art. 99, inc. 1°) y el Jefe de Gabinete de Ministros *ejerce* esa administración general (art. 100, inc. 1°).

Cuando Cassagne (10) afirma que el *Presidente* tiene la *titularidad* de la jefatura de la administración y que el *ejercicio* de esa jefatura le incumbe al *Jefe de Gabinete* realiza una distinción entre la titularidad y el ejercicio de la competencia. Del mismo modo, aclara que "en rigor, cuando la constitución prescribe que el presidente es el jefe de gobierno, lo que está diciendo es que es el jefe de la administración y el titular de la zona de reserva constitucional que pertenece al poder ejecutivo" (11). Finalmente, concluye que la *relación jerárquica* entre el presidente y el jefe de gabinete subsiste (12).

No obstante, Bidart Campos señala que, en realidad, "si se clausuran las facultades que solamente puede ejercer el jefe de gabinete, parece que en toda la gama de las demás competencias que le atribuye el texto reformado hay concurrencia con las del presidente, a condición de aceptar que éste inviste la titularidad en la jefatura de la administración, y que el jefe de gabinete inviste únicamente su ejercicio" (13).

6. ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO

El análisis de la palabra "administrar" ha dado lugar a varios significados, pues los clásicos utilizaron el término en latín con diferentes sentidos. Así

(8) CASSAGNE, JUAN CARLOS, *op.cit.*

(9) *Idem*.

(10) *Idem*.

(11) *Idem*.

(12) En idéntico sentido, CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 95.

(13) BIDART CAMPOS, *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, t. IV: "La reforma constitucional de 1994", Buenos Aires, 1995, p. 419.

Julio César le dio el sentido de mandar (*administro exertium*); Tito Livio, el de gobernar (*administro respublicam*); Cicerón, el de dirección (*aministratio portus*); y Quintiliano, el de conducir (*ars administrativa*) (14).

Del mismo modo, el jurista español Fernando Garrido Falla señala que el mencionado vocablo se forma con las palabras *ad ministrare*, que significa servir, o según otros, por contracción de *ad manus trahere*, que alude a la idea de manejo o gestión. Se desprende de lo anterior que la administración alude a la gestión de asuntos o intereses; pero una gestión *subordinada*. Asimismo, Jellinek concuerda con Garrido Falla en la importancia de la etimología latina al analizar el término "administración". En tanto que Gullik señala que la función administrativa consiste en las siguientes actividades: planear, organizar, administrar el personal, dirigir, coordinar, informar y hacer los presupuestos (15).

Por último, Marienhoff (16) sostiene que "la administración es una actividad concreta y práctica que consiste en actos jurídicos y en operaciones materiales. Es, además, una actividad inmediata, pues la realizan y la llevan a cabo los propios órganos administrativos con el objeto de lograr los fines que la motiven".

Por otra parte, el vocablo "gobernar" ha sido considerado un término bastante ambiguo y polisémico. En el "Diccionario del Uso del Español", María Moliner, define "gobernar" como "regir o dirigir una colectividad dictando las disposiciones para su marcha ordenada y haciéndolas cumplir y, específicamente, dirigir en esa forma un país o colectividad política".

Como consecuencia de la diversidad de significados otorgados a las palabras "administración" y "gobierno" han surgido diversas posturas relacionadas con la figura del Jefe de Gabinete. Tal es así como algunos han creído ver una figura que ejerce funciones gubernativas, en tanto que otros, desde una perspectiva más restringida a la letra de la Constitución Nacional, conciben al mencionado Jefe como un mero ejecutor de la administración general del país.

Asimismo, debemos tener presente que tanto en la vieja Constitución de nuestro país como en el sistema estadounidense, el Presidente de la República detenta la jefatura de Gobierno y la de la Administración. Quizá haya sido por esa razón que se confundió administración y gobierno, llegando a utilizar ambos términos como sinónimos, sin hacer discriminación alguna y con todas las consecuencias no deseadas de tal utilización. En los sistemas denominados parlamentaristas la administración está comprendida en el gobierno (17).

(14) BARCIA, ROQUE, *Diccionario General Etimológico*, t. I, Madrid, 1880.

(15) GARRIDO FALLA, FERNANDO, *Tratado de Derecho Administrativo*, vol. I, Parte General, Madrid, 2002.

(16) MARIENHOFF, M. S., *Tratado de Derecho Administrativo*, t. I, Buenos Aires, 1995.

(17) BARRAZA Y OTRA, op. cit.

En concordancia con lo expuesto, cabe aclarar que la prensa argentina ha colaborado con la confusión de los términos sujetos a análisis. Esto se puede observar en frases como "la administración De la Rúa", "la administración Kirchner", "la administración Bush". Quizás la última frase sea el punto de partida para comprender de dónde ha surgido esta confusión. Así, se hace necesario trasladarnos al idioma inglés para analizar una de las acepciones de la palabra "administration". La acepción que importa analizar a los fines de aclarar esta cuestión hace referencia al gobierno de un país en un momento determinado (18). El ejemplo "the Kennedy Administration" —extraído del "Longman Dictionary of Contemporary English"— parece aclarar el uso que se le ha dado últimamente al término "administración". El mismo diccionario nos ofrece también el siguiente ejemplo: "The problem has been ignored by successive administrations". Este último ejemplo hace referencia a un problema que no ha sido solucionado por gobiernos sucesivos, ya que —en este contexto— no resultaría claro establecer que las sucesivas administraciones desconocieron el problema.

Si bien el término "administración" puede usarse con el significado —de reciente admisión— de "equipo de gobierno que actúa bajo un presidente" (por ejemplo: "la administración Menem") (19), no se corresponde con el significado de "administration" analizado. De este modo, la confusión se acentúa, pues normalmente la palabra "administración" se utiliza incorrectamente como sinónimo de "administration" y, según lo expuesto, el término inglés se encontraría más cercano al significado de "gobierno".

En el contexto legal, es muy usual utilizar la expresión "Poder Administrador" para referirse al "Poder Ejecutivo", expresión cuya utilización no sería correcta desde el punto de vista de la teoría material. La confusión de identificar al Poder Ejecutivo como "Poder Administrador" surge de la Revolución Francesa. Así se traza una línea de pensamiento donde la Administración se confunde con Poder Ejecutivo, conforme al concepto clásico de división de poderes. En consecuencia, desde esta perspectiva, el derecho administrativo vendría a ser el régimen jurídico especial del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, en el texto de nuestra Constitución Nacional, se alude al Presidente de la Nación como "jefe de Gobierno" y "responsable político de la administración general del país", mientras que se le asigna al Poder Legislativo la preeminencia en la atribución legislativa y al Poder Judicial una preeminencia en la atribución judicial.

Quizás ésta sea la razón por la cual gobierno y administración son funciones ligadas a la figura del Poder Ejecutivo, sin pretender desconocer que existen matices en la labor de cada uno de los poderes que nos impidan adscribir a una postura subjetiva.

(18) Extraído del *Longman Dictionary of Contemporary English*, cuya versión original establece: "the government of a country at a particular time".

(19) OLSEN DE SERRANO REDONNET, M. L. y ZORRILLA DE RODRÍGUEZ, A. M., *Diccionario de los usos correctos del español*, Buenos Aires, 1997.

En este sentido, Rafael Bielsa (20) ha sostenido que Poder Ejecutivo y gobierno han pasado a ser sinónimos en lenguaje legal y doctrinario con todos los inconvenientes de una grosera confusión.

Germán Bidart Campos (21) ha sostenido la tesis material, reconociendo que la función administrativa se da en órganos que nos son parte del Poder Ejecutivo. Conforme a esta teoría la Administración Pública, aunque depende del Poder Ejecutivo, no formaría parte de él. Por el contrario, el citado autor considera que la administración se diversifica en órganos y tipos de actividad que sólo se le subordinan jerárquicamente.

Sin embargo, existen autores de gran relevancia, como Fritz Fleiner, que desconocen la teoría materialista y adhieren a una postura subjetiva. El autor referido define la administración como toda actividad que el Estado o cualquiera otra corporación de derecho público desarrolla, en su propio orden jurídico, para alcanzar sus fines esenciales, y no pertenece a la esfera de la legislación ni de la administración de justicia (22).

Por otra parte, el autor español Alejandro Nieto (23) señala que "lo fundamental, en todo caso, es que la actuación administrativa venga precedida por una norma general para evitar la arbitrariedad y la desigualdad; y que cada norma respete el orden jerárquico encabezado por la ley o, si se quiere, por la Constitución".

En el mismo sentido, el jurista argentino Villegas Basavilbaso (24) entiende que "el Estado moderno tiene límites en su actividad, demarcados por normas de Derecho y, por lo tanto, la Administración, que es una de sus manifestaciones jurídicas, debe obrar normalmente en la órbita de aquéllas". Es conveniente aclarar que este autor define a la Administración como "una de las funciones del Estado que tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas por actos concretos, dentro del orden jurídico y de acuerdo con los fines de la ley".

Por último, el concepto de gobierno ha sido descrito por el español Jorge Xifra Heras (25), quien expresó que "se entiende por gobierno la alta dirección, la impulsión que parte del centro para activar los negocios en el sentido de una buena política y del interés general. La acción complementaria de 'gobierno', subordinada al mismo, es 'Administración'. El gobierno sería el motor. Los funcionarios de la Administración serán los órganos de transmisión y las piezas de la máquina".

(20) BIELSA, RAFAEL, *Derecho Administrativo*, t. I, Buenos Aires, 1955, p. 180.

(21) BIDART CAMPOS, GERMÁN, *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, t. II: "El Derecho Constitucional del Poder", Buenos Aires, 1993, p. 303.

(22) FLEINER, FRITZ, *Instituciones de Derecho Administrativo*, Barcelona, 1933.

(23) NIETO, ALEJANDRO, *La Organización del Desgobierno*, Barcelona, 1984.

(24) VILLEGAS BASAVILBASO, BENJAMÍN, *Derecho Administrativo*, t. I, Buenos Aires, 1949, ps. 1 y sigtes.

(25) XIFRA HERAS, JORGE, *Formas y Fuerzas Políticas*, Barcelona, 1958.

7. DIFERENTES TESIS FUNCIONALES

a) Tesis de la relación-supervisión

Humberto Quiroga Lavié (26) ha manifestado que "el jefe de Gabinete se encuentra en una situación de dependencia política en relación con el Presidente, de forma tal que aquél carecerá de la autonomía propia del jefe de Gobierno, como ocurre con el Primer Ministro en el semipresidencialismo francés". Por otra parte, el citado autor aclara que "no puede sorprender que en la Argentina el Jefe de Gabinete no se constituya en el jefe de Gobierno, como lo es en el semipresidencialismo francés, en razón de que en este sistema la mixtura del presidencialismo viene por el lado de haberle introducido una variable netamente parlamentaria al mismo: la jefatura del gobierno en cabeza del Primer Ministro es una variable claramente parlamentaria. En cambio, en nuestro país la atenuación del presidencialismo, en relación con la creación del Jefe de Gabinete no viene por vía de su parlamentarización, sino solamente por haberlo colocado a dicho funcionario a cargo de la administración general del país".

Abel Fleitas Ortiz de Rozas (27) coincide "en la existencia de una 'relación jerárquica' cuando el Jefe de Gabinete ejerce facultades delegadas por el Presidente, conforme lo previsto por el art. 100, inc. 4° de la Constitución. Pero no cuando actúa en ejercicio de atribuciones que le han sido otorgadas en forma directa por la Constitución: Administración general del país, nombramiento de los empleados de la administración, hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional".

De este modo, los doctrinarios que defienden esta teoría advierten que en los casos previstos específicamente en el texto de la Ley Fundamental, existiría un "vínculo de control administrativo" o una "relación de supervisión" entre el Poder Ejecutivo y el Jefe de Gabinete de Ministros.

b) Tesis de la relación-jerárquica

Uno de los argumentos más utilizados para defender esta postura es el texto del art. 99, inc. 7° de la Constitución Nacional que establece que el Presidente de la Nación "por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros".

Si bien existe la posibilidad de remoción del Jefe de Gabinete de Ministros por parte del Congreso de la Nación (art. 101), este procedimiento no ha otorgado a nuestro Parlamento la facultad de nombramiento del Jefe de Gabinete. Tal es así que este intento de fortalecer el rol legislativo en contraste con el Ejecutivo queda incompleto, pues el Presidente de la Nación sigue conservando la facultad exclusiva de nombrar al Jefe de Gabinete.

(26) QUIROGA LAVIÉ, HUMBERTO, "El Jefe de Gabinete: Técnica dirigida a consolidar el sistema institucional de la República", LA LEY, Actualidad, 24/5/1994.

(27) FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, ABEL, "El jefe de gabinete de ministros: Perfiles e interrogantes", LA LEY, del 28/6/1995.

8. A MODO DE REFLEXIÓN

Un reconocido número de juristas considera que la única jefatura extraf-
da a partir de la reforma de 1994, fue la de la Capital Federal, mediante la
creación de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la elección directa
por parte del pueblo del jefe de gobierno de dicha ciudad (art. 129).

De otro modo, se ha intentado delegar la administración general del país
mediante la inclusión de la figura del Jefe de Gabinete en el nuevo texto
constitucional para descentralizar el rol ejecutivo y el control de accionar del
Presidente. No obstante, Badeni ha encabezado a gran parte de la doctrina
que sostiene lo contrario, considerando que "bajo el pretexto de atenuar las
funciones del Presidente, en realidad se las incrementa alterando la esencia
del sistema presidencialista, el equilibrio resultante del principio de división
de los poderes y organizando un sistema que nos aproxima al umbral del
cesarismo empírico" (28).

En última instancia, el jefe de gabinete es un ministro más, e indepen-
dientemente de la magnitud de sus facultades, su dependencia del deseo
presidencial es categórica y absoluta, del mismo modo como ocurre con los
restantes ministros, respecto de los cuales el jefe de gabinete no ejercerá
tampoco ningún tipo de prerrogativa relacionada con su designación o re-
moción.

Cabe concluir que la figura del jefe de gabinete no constituye de ningún
modo un contrapeso efectivo de las prerrogativas presidenciales (29).



(28) BADENI, G., "Atenuación del presidencialismo y el cesarismo empírico", La Nación, del
21/3/1994.

(29) SABSAY y ONAINDIA, op. cit.

CAPITULO II.3

LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Concepto y características. — 3. Análisis
jurisprudencial. a) "Peralta". b) "Video Club Dreams". c) "Rodríguez, Jorge".
d) "Verrochi". e) Comparación con el caso "Rodríguez". f) "Risolia". — 4. Revi-
sibilidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia. — 5. Comisión Bicameral
Permanente. — 6. Actitud del Poder Legislativo en los Decretos de Necesidad
y Urgencia. — 7. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN

En las repúblicas democráticas cuya sustancia se constituye con la divi-
sión y el control del poder, estos últimos son múltiples y de fuente diversa (1).
La amplitud, coloratura y ejercicio de los controles institucionales depende
del modelo gubernamental, presidencialista o parlamentario, de cómo se
anuden las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y desde luego, tam-
bién del modo en que aquellos poderes se ejercen por sus detentadores (2) y
de cuán visible resulta para la opinión pública aquella manera de emplear el
poder (3).

En la República Argentina, antes de la reforma constitucional de 1994, los
decretos de necesidad y urgencia proponían —de igual modo que la promul-
gación parcial de leyes y la delegación legislativa— un sinnúmero de proble-
mas constitucionales, el principal de ellos referido a la legitimidad de tales

(1) Karl Loewenstein definía a la Constitución por sus controles, examinando la impor-
tancia de los controles verticales que emergían de la opinión pública, la pluralidad social, en
fin, de los factores y grupos de poder. Conf. LOEWENSTEIN, KARL, *Teoría de la Constitución*, Barce-
lona, 1976.

(2) Sin postular la existencia de un derecho constitucional consuetudinario, la manera en
que se resuelven las dudas interpretativas o se da forma a las decisiones por los órganos de
poder, van modelando las normas constitucionales, otorgándoles sentido y significado, con-
forme a la Constitución o en contra de ella.

(3) Tanto los abusos de poder como la eventual corrupción en la toma de decisiones
—incluidas las decisiones legislativas— se limitan cuando se informa críticamente acerca de
ello. De ahí la importancia y funcionalidad de la libertad de expresión en las democracias
modernas.

prácticas. Ello así, pues la norma expresa de la Constitución histórica no establecía esas atribuciones, aunque parte de la doctrina las entendió derivadas de facultades implícitas.

Comadira sostuvo que las jefaturas de la Administración y del Estado imponían al Poder Ejecutivo el deber de dictar decretos de necesidad y urgencia para preservar la subsistencia del Estado. Este deber derivaba, implícitamente, del entonces art. 86, inc. 1º—hoy art. 99, inc. 1º de la Constitución Nacional— (4).

Por su parte para Bianchi, al Congreso Nacional se le había atribuido la facultad de disponer la delegación impropia en el Poder Ejecutivo, en virtud del entonces art. 67, inc. 28—hoy art. 75, inc. 32— (5).

Sin embargo, la habitualidad con que el presidente recurría a los decretos de necesidad y urgencia para resolver crisis económicas y sociales, primero, y para zanjar sus disputas con el Congreso después, viró la perspectiva crítica de su empleo reiterado, a la carencia de controles eficaces ante su abuso.

No nos olvidemos, como gusta recordar a Diego Valadés, que “por definición, controlar al poder es un acto de poder” (6). Esos controles recortan y dimensionan las facultades y el haz de competencias de cada órgano del gobierno del Estado.

Por ello, en la Convención Constituyente de 1994 se concedió al presidente la atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia, estableciéndose, al mismo tiempo, una serie de controles procedimentales y sustantivos que implicaron límites lamentablemente no siempre muy precisos para su dictado. Pero, ya antes de la reforma constitucional, la Corte Suprema en el caso “Peralta” (7) había tenido ocasión de considerar la práctica presidencial de dictar aquellos decretos, o reglamentos de necesidad y urgencia como también se los llamó (8).

Por lo tanto, si bien su reglamentación surge del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional (9), su más riguroso análisis y extensión conceptual surge de la jurisprudencia y la doctrina.

(4) “Decretos de necesidad u urgencia en la reforma constitucional”, LA LEY, 1995-B, 825.

(5) “Los reglamentos delegados luego de la reforma constitucional” en *Derecho Administrativo*, Libro colectivo en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires, 1998, p. 79.

(6) VALADÉS, DIEGO, *El control del poder*, Buenos Aires, 2005, p. 17.

(7) Fallos: 313:1513 (1990); LA LEY, 1991-C, 158.

(8) GELLI, MARIA ANGÉLICA, “Controles sobre los decretos de necesidad y urgencia”, LA LEY, 14/2/2000.

(9) Art. 99. — “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... Inc. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen

2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Los decretos de necesidad de urgencia (en adelante “DNU”) no son una herramienta del siglo pasado. La doctrina ha detectado su presencia ya en la carta de restauración francesa, en donde se los denominaba “Decretos para la seguridad del Estado”. Esto nos indica que podemos afirmar que estos existen desde los orígenes del constitucionalismo moderno. Así también en la ley fundamental de Prusia de 1850 están previstos en su art. 53 en forma expresa para el caso de receso legislativo.

En numerosas constituciones europeas, estados con convicción democrática han empleado la posibilidad de existencia de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma expresa con la intención de limitarlas y de condicionarlas. Quizás una buena muestra de ello sea la constitución de España, las nuevas constituciones sudamericanas como las de Brasil, Colombia, Perú y la de nuestro país que han contemplado también estas normas siguiendo una fuerte inspiración doctrinal europea (10).

También bajo la influencia europea se encuentra en las modernas cartas de los Estados provinciales de Salta, San Juan y Río Negro.

A nivel nacional, en su *aspecto formal*, la sanción del DNU es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y debe ser decidido “en acuerdo general de ministros”, quienes, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, deberán refrendarlo. Este es un requisito que hace a la validez formal del reglamento, susceptible de revisión judicial.

Desde la perspectiva formal, la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario indica que la cuestión, la justificación habilitante, es estrictamente temporal y no referida a los alcances de la norma formalizada en el decreto de necesidad y urgencia. Este tendrá el mismo contenido de la ley que podría, de existir tiempo suficiente para ello, ser sancionada por el Congreso y, por su contenido, la validez de aquella norma será valorada de la misma manera en que lo sería la ley formal emanada del Congreso. La imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la formación y sanción de las

de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso...”

(10) En ese sentido, se ha argumentado en su contra en regímenes presidencialistas latinoamericanos como Argentina, Brasil y Perú. V. MIDÓN, MARIO A.R., *Decretos de Necesidad y Urgencia (en la Constitución Nacional y en los ordenamientos provinciales)*, Buenos Aires, 2001, p. 208.

leyes, es decir para la intervención del Congreso en la regulación de la cuestión que debe ser resuelta de manera urgente, es una mera circunstancia temporal, que depende del caso concreto, circunstancia que puede demostrar la inconveniencia de aguardar el normal trámite legislativo para responder con eficacia a la necesidad planteada.

En su *aspecto material*, la regla general, según el art. 99 inc. 3 de la CN, es la prohibición de la sanción de este tipo de normas, "salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes". Se trata de dos requisitos sustanciales habilitantes de la competencia para el dictado del DNU.

Examinemos un poco más esta temática:

- a) La razón de necesidad y urgencia, de naturaleza excepcional, en resolver una determinada situación política, social, económica o cualquier otra que precise de una determinada respuesta legislativa. Se trata de una situación de excepción (11), que la misma Corte en el considerando 24 del caso "Peralta" justifica la adopción de medidas restrictivas ante un grave riesgo social que pudiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado;
- b) Razonabilidad de las medidas adoptadas, en relación a la adecuación y proporcionalidad entre medios y fines. Además de la necesidad o imprescindibilidad de la medida dispuesta, debè efectuar la elección de la alternativa correcta entre muchas opciones de las que se tenga. Este último es considerado control fuerte de razonabilidad que muy pocos veces fue adoptada por nuestros tribunales de justicia.
- c) Análisis por parte del Poder Legislativo sobre la validez o invalidez de los DNU, siendo este último órgano político de control sustantivo en general, mientras que el particular le corresponde al Poder Judicial.
- d) Veda de determinadas materias taxativamente enumeradas en el art. 99 inc. 3 constitucional: materia penal, tributaria, relativa a los partidos políticos y al régimen electoral, en donde prevalece el principio de legalidad (12).

Resumiendo, los DNU son utilizados en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deban ser conjuradas sin dilaciones; solo frente a dichas situaciones puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso, siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a las circunstancias de excepción. En consecuencia, el ejercicio de la prerrogativa en examen está sujeto a reglas específicas, que exigen un estado de excepción y el impedimento de recurrir al sistema normal de formación y san-

(11) FERNÁNDEZ ASSELLE, DANIEL J., "Situación actual de los llamados 'decretos de necesidad y urgencia'", Astrea (publicación on-line), 2002, p. 3.

(12) CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 159.

ción de las leyes y contemplan, además, una intervención posterior del Poder Legislativo. Por otro lado, las medidas que se adopten no están exentas del contralor judicial, que constituye la salvaguarda de los derechos individuales. Aunque se puede apreciar la actitud huidiza de dicho contralor (CSJN) a la hora de inspeccionar la razonabilidad que debe existir entre la legislación de emergencia y su impacto negativo sobre el corazón de los derechos fundamentales.

En líneas generales, la Corte no ha fallado a favor de la intangibilidad de los derechos fundamentales, sino por el contrario ha justificado la legislación de emergencia (13). La performance del control jurídico es bajísima; es que al lado de estas potestades, como mínimo debería haberse creado una acción popular declarativa de inconstitucionalidad para que pudiera recurrirse judicialmente la declaración de inconstitucionalidad tanto de los DNU como de la legislación delegada (14).

¿Es revisable la razón excepcional de necesidad y urgencia (15)? Ello es un aspecto que valorará el Congreso al momento de decidir si aprueba o rechaza el DNU, pero su último control lo realiza el poder judicial, con la diferencia que el Poder Legislativo puede ir más allá, controlando el mérito y conveniencia de la medida implementada atento que al ser un órgano político, su control político resulta no sólo facultativo sino obligatorio.

3. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

a) Caso "Peralta"

De la década del '90 hubo un caso que marcó un hito en la República Argentina y éste fue el caso "Peralta", donde por primera vez la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia, dictado en el contexto de una grave crisis económica y social, producida por la hiperinflación. La norma convertía contratos bancarios a plazo fijo en bonos de la deuda pública. Debe señalarse que, más tarde, el Congreso Federal declaró la necesidad de reformar el Estado y la emergencia económica, por sendas leyes (16). En el precedente "Peralta" (17), el Tribunal estableció varias reglas referidas a las condiciones para el dictado de aquellos decretos y acerca de los controles institucionales, debidos y posibles.

(13) FERREYRA, RAÚL GUSTAVO, "Derecho y Emergencia", "¿Hay remedios contra el decretismo presidencial?", Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, edición N° 53, febrero 2002.

(14) VANOSSI, JORGE, LA LEY, 1994-E, 1260.

(15) La misma fórmula es de textura abierta, como ocurre con los conceptos que pueden provocar "decretos de urgencia" de acuerdo con la Constitución Peruana de 1993. V. LANDA, CÉSAR, "Los decretos de urgencia en el Perú", en "Pensamiento Constitucional", año IX, núm.9, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, p. 139.

(16) Ley 23.696 de Reforma del Estado 23/8/1989 y Ley 23.697 de Emergencia Económica (B.O. 25/9/1989) Adla, XLIX-C, 2444; XLIX-C, 2458).

(17) "Peralta, Luis Arcenio y otro c. Estado Nacional, Ministerio de Economía, Banco Central s/amparo", CS (1990), Fallos: 313:1513; LA LEY, 1991-C, 158.

136

En efecto, la Corte Suprema fijó una condición de legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia previa a su dictado; un recaudo de validez por el contenido de sus disposiciones y un requisito posterior, también de legitimidad por medio de la convalidación. Al mismo tiempo, la Corte Suprema ejerció controles y se reservó la facultad de analizarlos en el futuro.

En consecuencia, el Tribunal exigió para el dictado de los DNU: a) una situación de grave riesgo social que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado; b) razonabilidad de las medidas dispuestas en términos de: b') relación entre los medios elegidos por la norma y los fines de ésta; b'') examen de la proporcionalidad de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas; y b''') inexistencia de otros medios alternativos adecuados para lograr los fines buscados; c) convalidación del Congreso, expresa o tácita. Al establecer estos requisitos, la Corte Suprema ejerció control adjetivo y sustantivo de la norma cuestionada.

Acerca de los parámetros adjetivos, la Corte intensificó el control de la emergencia pero diluyó los controles del Poder Legislativo al admitir la ratificación tácita del Congreso, bastándole con que éste, pudiendo hacerlo, no dictase una disposición en contrario. Cabe aclarar, además, que para la Corte Suprema la legitimidad del decreto que se impugnó en "Peralta" derivaba, también de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Así, "Peralta" constituyó la convalidación jurisprudencial de los decretos de necesidad y urgencia, sin que la Constitución Nacional los regulara, y, al mismo tiempo, un caso de control judicial de la emergencia, pues la Corte Suprema la examinó y entendió que la había, calificando la situación que daba lugar a la norma de "grave riesgo social".

En este caso se comienza a diluir el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, mediante el parámetro impuesto por la misma Corte, la cual establecía la convalidación expresa o tácita por parte del Congreso.

b) Caso: "Video Club Dreams" (18)

El fallo de la Corte resuelve un recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal por la que se confirmó la de primera instancia, haciendo lugar a una acción de amparo interpuesta por Video Club Dreams, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 2736/91 y 949/92. Se funda en que dichos decretos crean impuestos, determinan los sujetos obligados al pago, fijan la base imponible y la alícuota, modifican la ley 17.741, tipifican infracciones y sanciones, erigiendo al Instituto Nacional de Cinematografía, en juez administrativo con facultades de fiscalización y de control.

(18) "Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía", CS, 6/6/1995, Fallos: 318:1154; LA LEY, 1995-D, 243.

Con dichos fundamentos, la sentencia resolvió que la solución de la controversia surge de la aplicación del principio de legalidad tributaria y la reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos, imposible de obviar mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

El fallo de la Corte, luego de resolver las cuestiones procesales interpuestas por el Instituto, y con relación al fondo del asunto consideró que el Poder Ejecutivo mediante un decreto extendió el hecho imponible creado por una ley a otro hecho imponible distinto y nuevo.

La Corte invocó un precedente propio en la causa "Eves Argentina S.A.", Fallos: para afirmar que no es compatible con nuestro sistema constitucional el dec. 2736/91 modificado por su par 949/92, en cuanto crea un hecho imponible distinto del previsto en la ley 17.741 (19). Con lo cual también cae por invalidez el acto impugnado mediante el cual se intimó al Video Club a ingresar el tributo.

Examina el voto mayoritario la concurrencia de los presupuestos de la doctrina del fallo "Peralta". Allí se fundamentó la atribución legislativa del Ejecutivo en la situación de descalabro económico generalizado y la supervivencia de la unión nacional: *El criterio de la Corte es que esa situación no se da en el caso, donde además está en juego el principio de legalidad en materia impositiva* (20).

Dado que la sentencia de Corte es posterior a la reforma, estos fundamentos son corroborados por el art. 99 inc. 3 donde son constitucionalizados los decretos de necesidad y urgencia, exceptuándose entre otras, la materia tributaria. Por lo que rechaza también los argumentos del Instituto en el sentido que la ulterior remisión de los decretos a la legislatura como así la inclusión de la incidencia del impuesto en el presupuesto para el año 1993, implican convalidación de lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia.

Vuelve aquí la Corte a ejercer el control de constitucionalidad de estos decretos, es decir de la atribución legislativa del Presidente, emanada del inc. 3 del art. 99, con base en la doctrina del fallo "Peralta" y en la aplicación del principio de legalidad en materia tributaria.

c) Caso: "Rodríguez Jorge" (Fallos: 320:2851)

Jorge Rodríguez en su carácter de jefe de Gabinete de Ministros se presenta directamente ante la Corte, denunciando un grave conflicto de poderes, suscitados con motivo de la medida cautelar dictada en la causa "Nieva Alejandro c. Poder Ejecutivo Nacional - decreto 842/97, s/medida cautelar autonomía", mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos del referido decreto.

(19) Consid 13 "Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía".

(20) Consid. 14 "Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía".

137

Vale la pena mencionar que este decreto de necesidad y urgencia, se dictó para ratificar dos decretos anteriores del PE que mandaban llevar a cabo la privatización de los aeropuertos, contra los cuales varios legisladores nacionales y el Defensor del Pueblo interpusieron acción de amparo.

En su presentación ante la Corte, el Ministro Rodríguez, plantea la falta de atribuciones del Poder Judicial para controlar los Decretos de necesidad y urgencia, toda vez que la Constitución fija un procedimiento especial a través de la intervención del Congreso. Plantea de este modo la incompetencia de los jueces para intervenir en la causa basándose en el art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58.

La pretensión sometida a decisión judicial por los legisladores tuvo por objeto la declaración de nulidad del decreto de necesidad y urgencia 842/97 sobre el marco regulatorio y privatización del servicio aeroportuario por haberse impedido la facultad de legislar de los accionistas y contrariar las disposiciones constitucionales que condicionan la validez de este tipo de actos emanados del Poder Ejecutivo.

La cuestión se resolvió en razón de la falta de "caso" y de agravio a los legisladores accionantes. El voto mayoritario de la Corte, resolvió que la jueza de grado había actuado en ausencia de jurisdicción (21) con lo que aparece nuevamente el tema de las *cuestiones políticas no judiciales*.

Sin embargo en varios *obiter dicta* acerca de los decretos de necesidad y urgencia, su alcance y controles, expresa por ejemplo, que la cláusula constitucional del art. 99 inc. 3 fija un procedimiento específico de contralor en sede parlamentaria y que dicho contralor no se encuentra subordinado en su operatividad a la sanción de la ley especial ni a la creación de la comisión bicameral permanente.

Lo contrario implicaría que la omisión legislativa privaría *sine die* al titular del Ejecutivo de una potestad conferida por el constituyente. Que en tales condiciones el decreto en cuestión no presenta defectos formales ni aparece dictado fuera del complejo normativo que regula su dictado.

La Corte en el considerando 18 fundamenta su decisión en que no puede intervenir en una contienda suscitada entre el Ejecutivo y algunos miembros de la Cámara de Diputados, y que la cuestión propuesta debe resolverse en el ámbito del Congreso a quien corresponde la valoración política que habilita la facultad excepcional del Ejecutivo así como de la oportunidad, mérito y conveniencia de su contenido.

Sin embargo y en evidente contradicción manifiesta que haber sostenido que la jueza carecía de jurisdicción no implicaba convalidar el decreto de necesidad y urgencia, en tanto esa norma es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales, antes, durante o después de su tratamiento legislativo (22).

(21) Consid. 24 voto mayoría en "Rodríguez Jorge en: Nieva Alejandro c. Poder Ejecutivo Nacional", CS, 1997, LA LEY, 1997-E, 884.

(22) Cons. 23 del voto de la mayoría en "Rodríguez Jorge en: Nieva Alejandro c. Poder Ejecutivo Nacional", CS, 1997, LA LEY, 1997-E, 884.

De esta forma, la Corte excluye del control de constitucionalidad esta facultad legislativa del Ejecutivo, con lo cual al decir del voto en disidencia del Dr. Fayt, considerando 10: "... Se incurre de este modo, en la incongruencia de atribuir supremacía al Poder Ejecutivo, quien en ejercicio de su facultad de legislar por decretos de necesidad y urgencia, estaría por arriba de la potestad legislativo del Congreso y naturalmente, del Poder Judicial". Quien también pone de resalto (23) que el Poder Ejecutivo no logra demostrar la necesidad y urgencia de otorgar la concesión de los aeropuertos, toda vez que su control se encuentra en la órbita de la Fuerza Aérea Argentina y la cuestión de su privatización en la sede del Congreso de la Nación donde el proyecto tiene dictamen favorable de las comisiones de presupuesto y hacienda y de transporte de la Cámara de Diputados.

Este fallo suscitó la reacción de la doctrina por ser un típico caso de conflicto o tensión entre el ejercicio de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, por el Presidente y el control judicial sobre los mismos. También implicó el ejercicio de la toma de decisiones en materia de políticas públicas del ámbito de competencias del Congreso por el Presidente.

d) Caso "Verrochi" (Fallos: 322:1276)

El Poder Ejecutivo en el año 1996 emitió los decretos 770/96 y 771/96 mediante los cuales suprimió las asignaciones familiares a los trabajadores con remuneraciones superiores a mil pesos; dichas normas derogaban también la ley 18.017 y sus decretos reglamentarios.

El actor, Verrochi, al ver lesionado su derecho a percibir junto con la remuneración las asignaciones familiares, las cuales concretan la garantía de la protección integral de la familia, contenida en el art. 14 bis, CN, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22, interpuso acción de amparo solicitando se declarase la inconstitucionalidad de dichas normas. Esta pretensión fue acogida por los tribunales de primera y segunda instancia.

Ante la respuesta de la segunda instancia, efectuada por la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el demandado, Fisco Nacional, interpuso recurso extraordinario que fue concedido. En su defensa afirma que los decretos en cuestión no desconocen derechos consagrados en el art. 14 bis de la CN y que contienen un sistema justo y equitativo respecto de las asignaciones familiares, que asegura la protección de los trabajadores de menores ingresos.

La Corte señaló con respecto a la posibilidad de emitir reglamentos de necesidad y urgencia que a partir de la reforma del año 1994 en la nueva redacción del art. 99 inc. 3 se admite el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo pero sólo bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales.

(23) Consid. 20, "Rodríguez Jorge en: Nieva Alejandro c. Poder Ejecutivo Nacional", CS, 1997, LA LEY, 1997-E, 884.

138

Como surge del fallo se le reconoce al Poder Ejecutivo esta facultad (la de dictar decretos de necesidad y urgencia), a pesar de que aún no había sido sancionada la ley especial contemplada por el art. 99 inc. 3 de la CN donde establecía la vigencia de la Comisión Bicameral Permanente. También dejó claro que la falta de sanción de una ley especial que regule el trámite y los alcances de la intervención del Congreso refuerza la responsabilidad por el control de constitucionalidad que es inherente al Poder Judicial de la Nación.

Concluyó la Corte que, debido a que el decreto en cuestión derogaba una ley formal, el Poder Ejecutivo Nacional había ejercido una actividad materialmente legislativa, con injerencia en la función propia del Congreso de la Nación correspondiendo por lo tanto al Poder Judicial el control de constitucionalidad.

Recordemos también que ya anteriormente, la Cámara había señalado que, habida cuenta de que los decretos derogaban la ley 18.017 y excluían de sus previsiones a los trabajadores con remuneración mensual superior a los mil pesos (arts. 2º y 11 del decreto 770/96), carecían de razonabilidad también en cuanto a su sustancia y merecían la tacha de inconstitucionalidad, puesto que privaban totalmente al actor de beneficios gozados durante años bajo la ley 18.017. Máxime cuando se trata de derechos sociales que pueden y deben ser reglamentados por las leyes formales, pero nunca aniquilados, ni aún en la emergencia. Con tales argumentos declaró la invalidez de los decretos cuestionados.

Además, y contrariamente a lo que sostuvo el demandado, señaló la Corte que es atribución del tribunal evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, descartó criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, ya que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.

Finalmente, la Corte consideró que no existió ninguna de las circunstancias fácticas que la norma constitucional describe en el art. 99 inc. 3 debido a que las afirmaciones vertidas en los considerandos de tales decretos resultan dogmáticas e insuficientes, no alcanzando a justificar la imposibilidad de ejercer la función legislativa del Congreso de la Nación.

Por lo tanto, se entendió que dicho decreto era constitucionalmente nulo de nulidad absoluta e insanable, en tanto priva al accionante de prestaciones que otorgan operatividad a las cláusulas superiores de "protección integral de la familia" y la "compensación económica familiar", que responden al requerimiento de los principios de un orden social justo y que solo podrían ser objeto de modificaciones mediante una ley del Congreso (24).

(24) Del voto del doctor Boggiano.

Con este tipo de conductas por parte del Poder Ejecutivo Nacional "se desnaturaliza la finalidad, de brindar una solución rápida y eficaz, que tuvo el constituyente al receptar la posibilidad de que bajo circunstancia de emergencia el presidente pudiera dictar resoluciones de este carácter".

Por ello, en la buena senda, la Corte Suprema de Justicia, en el caso "Verrocchi" dejó sentado que para la procedencia de estas disposiciones tenía que ser imposible seguir el trámite ordinario en la sanción de una ley, como sería el caso de que las cámaras no pudieran reunirse por causa de fuerza mayor o que la situación fuere de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente. También el máximo tribunal dijo que no era suficiente la mera invocación de la situación de emergencia, circunscribiéndola a afirmaciones dogmáticas e insuficientes. La exigencia marcada por la Corte Suprema procura impedir que el presidente tomara casi como una rutina recurrir al empleo de estos instrumentos pues, como lo manifestaron los jueces máximos en el aludido fallo, "...corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto" (25).

Es muy importante señalar aquí el papel fundamental de intérprete máximo que conlleva en sí misma la Corte Suprema, ya que dicha institución es la encargada de delinear con exactitud, caso por caso, la real, verdadera y única interpretación final de la norma.

e) Comparación entre el Caso "Rodríguez" y "Verrocchi": diferentes criterios del control o intervención del Poder Judicial sobre los decretos de necesidad y urgencia

La Corte en el año 1997 sostuvo en el caso "Rodríguez" (26) que la decisión de la jueza había sido tomada con ausencia de jurisdicción, o sea, había decidido un conflicto por naturaleza ajena a la resolución judicial que traduciría la invasión de la zona de reserva de otro poder.

En este mismo fallo la Corte resolvió, basándose en la falta de agravio concreto, no realizar un control de constitucionalidad del decreto en cuestión sosteniendo que es al Congreso, órgano depositario de la soberanía popular, a quien la Constitución atribuye una excluyente intervención en el control de los decretos de necesidad y urgencia, entendiendo que tal función no puede ser interferida en el modo de su ejercicio por el Poder Judicial. De interferirse esta función estaríamos frente a una grave afectación de la división de poderes.

El Máximo Tribunal afirma que el Congreso tiene una atribución excluyente en el control de los decretos de necesidad y urgencia pero reconoce al

(25) LON, FÉLIX, "Derecho y Emergencia". "Afirmar el imperio de la Constitución", Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, edición Nº 53, febrero 2002.

(26) LA LEY, 1997-F, 884.

Tribunal facultades para ejercer el control —aunque no deja muy en claro el alcance del mismo— ante agravio concreto en el que la norma cuestionada se considerase en pugna con los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

En este fallo ("Rodríguez") el Alto Tribunal sostuvo que se trataba de una cuestión política no judicializable y que en caso de inmiscuirse en la oportunidad y conveniencia del dictado del decreto se corría el riesgo de que la decisión política del gobierno fuese sustituida por un acto judicial que, aunque revestido jurídico-constitucionalmente, es en el fondo un acto político de personas que no tienen ningún mandato democrático para llevar a cabo esta función.

El caso "Verrocchi" difiere en muchos aspectos del caso "Rodríguez". En el primero, hay un derecho de un particular concretamente lesionado por los decretos dictados (derecho a percibir asignaciones familiares); esto fue lo que justificó que la Corte mediante el control de constitucionalidad los invalidase.

Y además sostuvo que se trataba de una cuestión judicializable. En "Rodríguez" el Tribunal verificó simplemente que el decreto cumpliera con los requisitos formales y sostuvo que cumplimentados los mismos la norma sólo podía considerarse sometida al pertinente contralor del Poder Legislativo, a quien corresponde pronunciarse acerca de la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de la facultad excepcional del Poder Ejecutivo, así como de la oportunidad, mérito y conveniencia de su contenido.

En el caso "Verrocchi", en cambio, la Corte admitió el control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial sobre las condiciones bajo las cuales se admite la facultad excepcional de dictar decretos de necesidad y urgencia. En este fallo, además, se señaló que es atribución del tribunal evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia, no limitándose el control ejercido por el Poder Judicial a meras cuestiones de forma.

La Corte en este caso efectúa un control amplio e intenso; en cambio, en el caso "Rodríguez" el Tribunal reduce el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia hasta casi hacerlo desaparecer.

Tanto en el caso "Rodríguez" como en "Verrocchi" la Corte coincide en que la falta de sanción de la ley especial contemplada por el art. 99 inc. 3 de la CN y el hecho de que no se encontraba en vigencia la Comisión Bicameral permanente no podía impedirle al Poder Ejecutivo el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia.

El tribunal sostuvo en el caso "Verrocchi" que esta circunstancia exigía un mayor control por parte de los jueces; en cambio, en el fallo "Rodríguez" se hace hincapié en el control legislativo.

En el voto del Dr. Petracchi le otorga un matiz distinto al fallo, al analizar el proceso de convalidación del decreto de necesidad y urgencia, de una

forma particularmente disidente con sus colegas. Analizando la fuente del art. 99, inc. 3º, según los debates en el seno de la Convención Constituyente de 1994, el ministro Petracchi sostiene que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia constituye un acto complejo, integrado por la voluntad presidencial y la intervención del Congreso (27). Ya que "el régimen de los decretos de necesidad y urgencia que adoptamos es el español", por lo que parece imprescindible recurrir a la fuente del sistema instaurado por la Reforma de 1994, esto es, la Constitución Española de 1978 cuyo art. 86.1 establece: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes...". "2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El congreso habrá de pronunciarse expresamente en dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario...".

En consecuencia, sin la voluntad integradora del Congreso, los decretos de necesidad y urgencia carecen de legitimidad constitucional (28). A mayor abundamiento y con duros términos para la doctrina "Peralta" sobre la validez de la aprobación tácita por parte del Congreso, este voto particular sostiene que el silencio del Poder Legislativo implica desaprobación (29). Por lo tanto, no acepta bajo ningún término la convalidación tácita del Congreso por lo anteriormente expuesto. Se infiere de dicha concepción que para que un decreto de necesidad y urgencia tenga viabilidad en cuanto al proceso que tiene que atravesar para ser válido es necesaria y obligatoria la convalidación expresa del Congreso de la Nación. Se observa con claridad el carácter disidente del Dr. Petracchi con respecto a los otros magistrados del Supremo Tribunal, ya que estos últimos reconocen la atribución presidencial de emitir decretos de necesidad y urgencia sin ley reglamentaria dictada por el Congreso Nacional.

La minoría de "Verrocchi" se hace cargo y defiende la postura de la mayoría en "Rodríguez", que tantas críticas doctrinarias había despertado (30).

f) Caso: "Risolfi de Ocampo María José c. Rojas Julio Cesar s/ ejecución de sentencia" (31)

En este caso se cuestiona la validez constitucional del decreto 260/97, dictado en ejercicio de las facultades que el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional concede al Presidente de la Nación, por el cual se declaró en estado

(27) Consid. 10, concurrencia de Petracchi.

(28) Consid. 13, concurrencia de Petracchi.

(29) Doctrina española (conf. SALAS, JAVIER, ps. 302/303).

(30) CARNOTA, WALTER F., "El control de constitucionalidad ante los decretos de necesidad y urgencia", LA LEY, 29/12/1999, ps. 1 y sigtes.

(31) "Risolfi de Ocampo María José c. Rojas Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente)", Fallos: 323:1955, 2/8/2000.

140

de emergencia a las empresas de autotransporte público de pasajeros y a sus aseguradoras.

Llega a la Corte por recurso extraordinario interpuesto por la demandada ante la sentencia de la sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmatoria del fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1º, 2º, 3º y 4º del decreto 260/97.

La Cámara consideró que para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, en primer lugar, debía darse una situación de grave riesgo social, frente a la cual fuese imperioso adoptar medidas urgentes. Como segunda condición, estableció que una norma de emergencia debe tender a la protección de los intereses generales de la sociedad y no de un grupo y finalmente que el decreto debe respetar el principio de igualdad. Dado que el decreto en cuestión no reunía estos requisitos, no pasó el "test" o examen de constitucionalidad.

El fallo de la Corte, luego del dictamen del Procurador Dr. Becerra, favorable a la constitucionalidad del decreto, por los votos de los Ministros Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert y Vázquez, con la única disidencia del Dr. Moliné O' Connor, declaró la inconstitucionalidad del decreto 260/97.

El voto mayoritario consideró que el referido decreto no cumplía con los requisitos exigidos para su validez, por cuanto se apartó no sólo de la doctrina de la Corte, sino también de las exigencias del nuevo texto constitucional del art. 99 inc. 3.

En sus fundamentos, se refiere con énfasis al requisito indispensable de que el decreto de necesidad y urgencia, tenga por finalidad proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos, extremo que no se cumple en el caso. Para agregar en el considerando siguiente, que la crisis de las empresas y compañías aseguradoras debe ser solucionada a través de los recursos usuales del Estado frente a crisis económicas.

En el mismo sentido, refiere al perjuicio que la aplicación de la moratoria producirá a las víctimas de las empresas, que no son precisamente las causantes de la situación económica que están pasando.

El voto del Dr. Belluscio, reivindica para el Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite el ejercicio de la atribución del dictado de decreto de necesidad y urgencia: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario, o 2) que la situación sea de una urgencia tal que debe ser solucionada inmediatamente. "No configurándose en el caso ninguno de los presupuestos fácticos para el ejercicio de las excepcionales facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a las exigencias rigurosas del texto constitucional" (32).

(32) Consid. 9, Dr. Belluscio, "Risolia de Ocampo María José c. Rojas Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente)".

g) Jurisprudencia posterior

La Corte Suprema ha ido zigzagueando en sus posturas sobre los apuntados decretos y el margen ("scope") del control judicial. Así, los distintos enfoques usados en "Guida" (Fallos:), "Smith" (Fallos:), "Tobar" (Fallos:), "Provincia de San Luis" (Fallos:) y "Bustos" (Fallos:) son cabal comprobación de esta afirmación.

Queda en claro, por lo demás, según lo expresado por la mayoría en "Provincia de San Luis" (sentencia del 5 de marzo de 2003), que el Ejecutivo no puede utilizar acumulativamente las herramientas de los DNU y de la delegación legislativa.

Como balance, podemos expresar que la Corte Suprema ha oscilado entre la abdicación del control y su plena inspección (33), resultando el contralor esquivo en el plano de las conductas. Prueba de ello es su uso generalizado: 10 DNU (Alfonsín), 543 (Menem); 73 (De la Rúa); 148 (Duhalde) y 170 (Kirchner, entre mayo de 2003 y mediados de 2006).

4. REVISIBILIDAD DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

En definitiva, los DNU exigen una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial, en el ejercicio de control de constitucionalidad. Esa mayor responsabilidad requerida por la Corte la asume en plenitud ella misma, al dar alcance interpretativo al art. 99, inc. 3º de la Constitución y establecer las condiciones bajo las cuales puede ejercerse la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia.

Así, el Tribunal se encuentra dispuesto a examinar si se cumplieron las exigencias materiales y formales en el dictado de aquellas normas que: a) se enmarcan dentro del principio republicano; b) mantienen intangible el sistema de mutuos controles entre los poderes; c) requieren la existencia de un estado de necesidad en términos de imposibilidad del Congreso para dictar normas, por ejemplo, en caso de una contienda bélica o de desastres naturales que impidan a los legisladores llegar a la Capital o que la situación que necesite solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente; d) desestiman razones de mera conveniencia para dictar los decretos; e) contengan suficiente motivación fáctica en los mismos considerandos de la norma cuestionada; y f) no aniquilen el derecho limitado mediante la norma.

Como se advierte de la enunciación que antecede, el control que efectúa la Corte Suprema es amplio e intenso. Por lo cual si se aplicara dicha doctrina en el caso "Peralta", posiblemente resultara inconstitucional el decreto en cuestión, ya que no resistiría las pautas o parámetros tan concreto y específicos, establecidos con mayor exactitud en el caso "Verrocchi". En este último

(33) CARNOTA, WALTER F., "Por fin, se reglamentaron los decretos de necesidad y urgencia y otros remedios de excepción", en www.eldial.com, agosto de 2006.

caso, se examina con mayor certeza el cumplimiento del debido proceso sustantivo y adjetivo y analiza la razonabilidad de la medida, exigiendo motivación concreta en los hechos y circunstancias que habrían impulsado la sanción de los decretos.

La Corte Suprema, saludablemente, parece no olvidar que el Estado de derecho es un estado de razón y que este debe manifestarse y concretarse expresamente en los motivos que la autoridad alega para limitar derechos o para ejercer atribuciones excepcionales (34).

En el caso "Rodríguez" la Corte sostiene que: "Contrariamente a lo que sostiene el recurrente: "... corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos, 318:1154, considerando 9) y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto".

5. COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE

Como hemos visto el decreto de necesidad y urgencia se encuentra sometido a un procedimiento especial, que incluye actuaciones que hacen a su validez formal, como la toma de decisión en acuerdo general de ministros, el refrendo conjunto por todo el gabinete y su envío al Congreso por parte del Jefe de Gabinete de Ministros ("personalmente", dice la norma, aunque no cabe interpretar que se trate de una exigencia "física") dentro de los diez días de su sanción.

De acuerdo con el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, el decreto de necesidad y urgencia enviado al Congreso por el Jefe de Gabinete, es sometido al estudio de una "Comisión Bicameral Permanente" (en adelante "CBP"), creada entonces por la propia Constitución, "cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara", dice la norma. Esta Comisión Bicameral es la misma que debe intervenir para el análisis de las promulgaciones parciales de leyes, efectuadas por el Poder Ejecutivo, mecanismo en principio prohibido salvo que las partes de la ley promulgadas gocen de "autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso" (art. 80 CN), decretos de promulgación parcial que deben ser puestos por el Jefe de Gabinete a la consideración de la Comisión Bicameral dentro del plazo de diez días de su sanción (art. 100, inc. 13 CN).

(34) V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada*, Buenos Aires, 2005, p. 845.

La "CBP" cuenta con un plazo de diez días para expedirse, en un dictamen que carece de efectos vinculantes para las cámaras de senadores y diputados, las que lo examinarán en reunión plenaria por separado (art. 99, inc. 3°, CN).

Como se ve la propia Constitución ha establecido las bases del procedimiento de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia por el Congreso, dejando sus detalles relativos al "trámite y a los alcances de la intervención del Congreso" (norma citada) a una regulación que deberá hacerse por "ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".

En "Rodríguez" la mayoría de la Corte optó por convalidar los DNU sin ley que reglamente la "CBP", con tres argumentos contundentes:

- 1) la omisión del Congreso no puede privar al Ejecutivo del ejercicio de una competencia otorgada por la Constitución, ya que de lo contrario la actividad propia de un poder quedaría sometida a la decisión discrecional de otro, que podría nunca cumplir con los cometidos que le impone la norma constitucional o, establecida la Comisión y sancionada la ley reglamentaria, disolver aquella y derogar la ley cuando quisiera evitar que el Presidente de la República dictase un decreto de necesidad y urgencia;
- 2) el Congreso puede revisar el decreto de necesidad y urgencia con los medios que hoy cuenta, aún sin el funcionamiento de la Comisión Bicameral y la reglamentación procesal;
- 3) de hecho esta última es la conducta del Legislativo con relación a la promulgación parcial de las leyes, donde los decretos pertinentes fueron sancionados por el Ejecutivo y revisados por el Congreso a pesar de la inexistencia de la Comisión Bicameral y de la ley reglamentaria. La doctrina de "Rodríguez" fue reiterada en "Verrocchi", expresamente por la minoría e implícitamente por la mayoría, que no utilizó la argumentación en contrario, salvo en el caso del voto concurrente del Dr. Petracchi ya referido.

El 20 de julio de 2006 se ha sancionado la ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación y la promulgación parcial de leyes.

Y con ella regula el funcionamiento de la "CBP", prevista en los arts. 99, inc. 3, y 100, incs. 12 y 13 de la Constitución Nacional, se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos mencionados.

Dicha comisión estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas (art. 3° de la ley citada). Y durarán en el ejercicio de sus fun-

792

ciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y pueden ser reelectos (art. 4º). La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación.

Anualmente se elige un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser reelectos. La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara (art. 5º). La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros (art. 7º).

Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente (art. 8º).

La comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de previsión en el reglamento interno y en todo aquello que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.

El art. 10 de la ley de rito, establece que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.

Por su parte, el Poder Legislativo debe dar expreso e inmediato tratamiento (art. 21). Pero el rechazo o aceptación no puede ser implícito (art. 22); en caso contrario podría darse la hipótesis de caer en una inconstitucionalidad por omisión.

En el supuesto de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete (art. 18).

Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los arts. 99, inc. 3 y 82 de la Constitución Nacional (art. 20).

Un dato muy significativo es el dado por el art. 6º donde establece que la CBP cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Este aporte echa por tierra el criterio que los DNU son una herramienta fundamental cuando está en receso el Congreso.

6. ACTITUD DEL PODER LEGISLATIVO EN LOS DNU

Por último, resta analizar las posibles actitudes del Congreso frente al decreto de necesidad y urgencia, habida cuenta que, como ya vimos, la sanción de esta norma obliga a aquél a actuar, salvo que prefiera, o no lo pueda evitar —por la carencia de las mayorías necesarias— que el decreto de necesidad y urgencia continúe con su vigencia plena.

El primer punto a considerar es que el Congreso debe expedirse expresamente. Así lo dice el art. 99, inc. 3º CN, cuando menciona que la Comisión Bicameral debe emitir su dictamen y enviarlo al plenario de cada Cámara "para su expreso tratamiento". Claro que podría sostenerse que el tratamiento debe ser expreso, aunque no la decisión. Sin embargo la inclusión del término "expreso" por el constituyente, que podría haber simplemente escrito "para su tratamiento", parece indicar un énfasis especial en la necesidad de una manifestación expresa por parte del Congreso. No hay tratamientos tácitos, mucho menos cuando se da en el plenario de cualquiera de las Cámaras del Congreso, donde el debate (aunque sea mínimo) es una regla que no conoce excepciones. Cuando la Constitución agrega la palabra "expreso" quiere indicar que exige que el dictamen de la Comisión Bicameral, y con él, el reglamento, sea debatido y votado, con lo cual habrá una manifestación expresa de voluntad de cada una de las cámaras legislativas.

Pero además esta norma constitucional debe leerse juntamente con otra, que impone un principio general también, lógicamente, vigente para el caso en examen. Se trata del art. 82 CN que establece: "La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta". Aunque esta disposición se refiere al proceso de formación y sanción de las leyes, también alcanza a otras manifestaciones de voluntad de las Cámaras —por ejemplo, resoluciones, comunicaciones al Poder Ejecutivo, etc.—, que por naturaleza deben ser expresas. Además, nada impide que la decisión acerca de un decreto de necesidad y urgencia tenga forma de ley y si la tuviera como resolución, volvemos a lo ya planteado: éstas deben ser, por su misma naturaleza, expresas. No puede haber leyes tácitas, ni tampoco ningún otro tipo de acto que manifieste la voluntad común del Congreso o la individual de cada Cámara.

Esta cuestión fue expresamente tratada en "Verrocchi" por el voto concurrente del Dr. Petracchi, proponiendo una solución que no parece ser la adecuada. Allí el mencionado Ministro, sobre la base de que nuestro art. 99, inc. 3º CN, según lo expuesto en el debate de la Convención Constituyente de 1994, encuentra inspiración en el art. 86 de la Constitución Española, hizo relación de la doctrina elaborada en función del citado art. 86, que atribuye "al silencio efectos similares a la desaprobación expresa del decreto-ley". En realidad la comparación es desacertada ya que la Constitución Española no tiene una norma como la contenida en el art. 82 de nuestra Constitución, con lo cual el intento comparativo fenece automáticamente. Por otra parte sorprende la interpretación dada al texto español, cuando es aún más enérgico que el nuestro en cuanto a exigir un pronunciamiento expreso del Legislativo. Así mientras

nuestro art. 99, inc. 3º dice que el despacho de la Comisión Bicameral será elevado al pleno de las Cámaras "para su expreso tratamiento", el art. 86 de la Constitución Española dice que "El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo (30 días desde la promulgación del decreto-ley) sobre su convalidación o derogación". Pero aun cuando a esta norma pudiere otorgársele un sentido contradictorio, lo cierto es que tal interpretación no es posible en nuestro medio, ya que lo veda el texto del art. 82 CN que prohíbe que "la voluntad" de cualquiera de las Cámaras pueda sancionarse de manera "tácita o ficta".

Se establece la caducidad automática tanto para el jefe de gabinete (art. 18 de la ley 26.122) como para la CBP (art. 20 de la ley citada). Por su parte el silencio del Congreso mantiene la vigencia del decreto de necesidad y urgencia, lo que, además de las razones ya expuestas, fortifica la seguridad jurídica. Poco efecto tendría una norma cuya vigencia quedase sometida a un plazo resolutorio breve, dependiendo exclusivamente de la inactividad del Congreso. De esta manera, el decreto de necesidad y urgencia carecería totalmente de efectos prácticos, traicionándose así, con la interpretación que se cuestiona, la clara intención del constituyente.

El Congreso debe, entonces aprobar o rechazar el decreto de necesidad y urgencia, expresamente.

La aprobación no modifica la situación jurídica existente, generada a partir de la sanción del decreto de necesidad y urgencia, aunque su conveniencia práctica, a los efectos de la seguridad jurídica, es evidente: *es la manifestación expresa de la conformidad del Congreso con el reglamento, lo que implica la imposibilidad de un rechazo posterior, sin perjuicio de que luego, como cualquier ley, el decreto pueda ser derogado o modificado por una ley ulterior.*

El rechazo, en cambio, provoca una radical alteración de la situación jurídica existente hasta ese momento, con efectos trascendentes. El rechazo puede tener diversos contenidos: a) porque el decreto de necesidad y urgencia legisló en cualquiera de las materias prohibidas por el art. 99, inc. 3º CN, lo que supone la nulidad absoluta del reglamento desde sus orígenes sin siquiera encontrarse protegidas las relaciones jurídicas de buena fe nacidas al amparo del decreto de necesidad y urgencia rechazado; b) por defectos formales en el decreto, como la falta de referendo por la totalidad del gabinete ministerial, falta de envío al Congreso, o envío tardío, con los mismos efectos que en el caso anterior aunque con protección de las relaciones jurídicas de buena fe, ya que se trata de defectos de imposible o difícil conocimiento para el común de la ciudadanía; c) por disconformidad con la valoración de la razón de necesidad y urgencia, o con la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de la ley formal, lo que también produce los efectos antes señalados, protegiendo a los "operadores" jurídicos de buena fe, para quienes esta cuestión es una materia de imposible valoración, ya que es exclusiva del Congreso; d) por disconformidad con el contenido del decreto de necesidad y urgencia, lo que equipara el rechazo con la ley posterior derogatoria, es decir el decreto de necesidad y urgencia mantuvo plena y válida vigencia hasta la sanción del rechazo.

Debe analizarse si el rechazo debe tener la forma de una ley o puede ser expresado por resolución conjunta o individual pero coincidente de cada una de las Cámaras. Podría optarse por la solución de la ley formal, sobre todo por razones de seguridad jurídica y porque permite el funcionamiento pleno de la Cámara de origen y Cámara revisora, lo que sería de difícil ejecución práctica en el supuesto de que el rechazo tenga la forma de una mera resolución.

Sin embargo esta solución presenta un inconveniente importante: si el rechazo se expresa a través de una ley formal, el Poder Ejecutivo podría vetarlo, manteniendo la vigencia del decreto de necesidad y urgencia hasta tanto el Congreso pueda insistir con la mayoría de dos tercios de los votos (art. 83 CN), mayoría que siempre es difícil de obtener. De esta manera podría burlarse el control que el Congreso debe ejercer sobre los decretos mencionados, otorgándole al Poder Ejecutivo la decisión última en la materia.

Revisado el problema desde esta perspectiva, se impone la solución del rechazo y obviamente, la aprobación, por resolución de las Cámaras, lo que debería quedar establecido en la ley reglamentaria prevista en el art. 99, inc. 3º de la CN. Se trata de simples resoluciones de cada una de las Cámaras; nada impide que puedan realizar una sesión conjunta, sin el procedimiento de cámara de origen y cámara revisora; con la coincidencia de ambas Cámaras ya se obtiene el rechazo. La norma constitucional establece que el despacho de la Comisión Bicameral será elevado al plenario de las Cámaras —lo que permite inferir que se trata de un envío simultáneo—, procedimiento que se ajusta en mayor medida con la celeridad que el constituyente quiso otorgarle al procedimiento de control por parte del Congreso. La citada ley reglamentaria debería regular la forma de envío de ambas resoluciones, de manera conjunta, al Poder Ejecutivo y la publicación, también simultánea y de ambas, en el Boletín Oficial.

Como ya vimos la preexistencia de una expresa aprobación impide el posterior rechazo, que sería así absolutamente inválido. Incluso si el rechazo posterior a la aprobación tuviese forma de ley, habría que interpretar a ésta como una mera derogación, que no afecta la vigencia del decreto hasta el momento de aquella ley derogatoria.

Pero ¿qué ocurre si no existió aprobación sino una conducta del Congreso que supone su aceptación del decreto de necesidad y urgencia?

Esta es una situación que puede ocurrir si el Congreso sanciona leyes que parten de la base de la vigencia del decreto, ej. si el reglamento crea una determinada entidad administrativa, y en la próxima ley presupuestaria, siempre sin expedirse sobre el decreto de necesidad y urgencia, el Congreso la dota de fondos para su funcionamiento. Entendemos que el rechazo sigue siendo válido, con sus efectos propios, aunque el tema es, sin duda, discutible, ya que el Congreso tiene la obligación constitucional de expedirse expresamente sobre el decreto de necesidad y urgencia, lo que sólo realiza con la resolución del rechazo (o en su caso, la de aprobación). Mientras tanto, aquellas leyes sancionadas por el Congreso, que suponen la vigencia del decreto

de necesidad y urgencia, ayudan a su presunción de validez y, por ende, a la situación de las relaciones jurídicas nacidas bajo el amparo del reglamento, que tendrán así, también, una fuerte presunción de buena fe. Por las mismas razones, el simple silencio del Congreso, que mantiene vigente el decreto, no impide el rechazo posterior (lo que demuestra la diferencia entre la aprobación expresa y el mero silencio, que nunca es aprobación sino una simple situación fáctica de vigencia de la norma de urgencia) por lo menos dentro del plazo en que el rechazo debe ser emitido, si la ley reglamentaria fija dicho plazo.

La derogación por medio de una ley anterior al debate de la Comisión Bicameral Permanente del decreto de necesidad y urgencia presenta una situación diferente. En estricto sentido se trata de una ley posterior que deroga, o podría también modificar, a una posterior. La derogación sólo puede sancionarse por ley formal y esta sí podría ser vetada por el Poder Ejecutivo y, a la vez, insistida por el Congreso. Esto es así, a diferencia de la situación que se plantea en el caso de rechazo, porque la derogación también supone que el decreto de necesidad y urgencia no fue rechazado y que por tanto fue plena y válidamente vigente hasta la promulgación y vigencia de la ley derogatoria.

Esta situación fue expresamente analizada por la Corte Suprema en el caso analizado: "Verrocchi". Aquí los decretos de necesidad y urgencia formalizados por decretos 770/96 y 771/96 fueron expresamente derogados por el art. 25 de la ley 24.714, lo que justificó la interpretación desarrollada por la minoría; la mayoría sólo hizo una rápida mención contraria en los votos de los Dres. Petracchi y Boggiano, con una conclusión absolutamente lógica: "solo es concebible por parte del órgano legislativo la derogación de normas cuya validez ha admitido" (considerando 12). Estrictamente hablando no se trata de que el Congreso, al derogar un decreto de necesidad y urgencia, "implícitamente" lo convalide hasta ese momento (es que tampoco puede haber aprobación implícita, violatoria también de la regla del art. 82 CN) sino que se aplica en el punto lo que hemos expuesto antes: mientras el Congreso guarde silencio, el decreto es vigente. Esta vigencia cesa a partir de la derogación, por ley, del decreto de necesidad y urgencia, en el clásico juego de norma posterior con respecto a norma anterior. Sin duda sería una conducta contradictoria del Congreso derogar una norma con respecto a la cual quiere rechazar su vigencia. Para esto último bastaría con resolver el rechazo del decreto, con los efectos ya vistos. Si deroga es porque admite que el reglamento, como consecuencia del silencio del Congreso, ha estado en vigencia, y lo está hasta el momento de la derogación.

7. RECAPITULACIÓN

La reforma constitucional de 1994 ha ubicado la competencia del Ejecutivo en materia legislativa, a través de la sanción de decretos de necesidad y urgencia, dentro de la disposición liminar del 99.3: "Participa —dice la norma en su párrafo inicial— de la formación de las leyes con arreglo a la Constitu-

ción, las promulga y hace publicar". Dentro de este cometido constitucional se encuentra el excepcional de sancionar los tan mencionados decretos, actos de naturaleza materialmente legislativa que también, desde el aspecto procesal, "participa(n) de la formación de las leyes" en colaboración con el Congreso, puesto que estos decretos quedan inmediatamente sometidos a la aprobación o rechazo por parte del Legislativo.

El art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional tiene así un alto contenido político pues impide la parálisis de la acción de gobierno (que en un sistema presidencialista es de extrema gravedad) por la falta de coincidencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando el primero no recibe el suficiente apoyo del segundo, lo que incluso puede suceder por la conducta de legisladores del propio partido oficialista. En definitiva, prevalecerá la decisión del Poder Legislativo (quien puede rechazar los decretos de necesidad y urgencia) pero ésta tendrá que ser expresa, previo debate, del que probablemente surja una ley con un contenido distinto que el del decreto de necesidad y urgencia rechazado, pero con algún contenido y no con el mero silencio.

Entonces no se trata de un ejercicio arbitrario del Ejecutivo que, por meras razones de conveniencia decide omitir la intervención del Congreso en el tratamiento de un determinado asunto. En realidad no la omite, sino que la provoca, la fuerza. El Congreso ya no podrá guardar silencio, pues de lo contrario el reglamento con efectos de ley continuará vigente. Aun cuando la decisión del Ejecutivo resulte irrazonable o arbitraria, pues no existe, en el caso, ni la necesidad, ni la urgencia, ni la excepcionalidad de la situación, el Congreso puede rechazarla en pocas horas y el Presidente o su Jefe de Gabinete de Ministros llevados al borde de la remoción, o a la remoción misma.

Es decir, se trata de una cuestión de relaciones políticas entre los dos poderes, cuyo juzgamiento es ajeno al rol, a la jurisdicción, incluso al "expertise" de los jueces.

Sin duda la decisión del Poder Ejecutivo de sancionar un decreto de necesidad y urgencia es de naturaleza discrecional, no reglada, que no debe ser arbitraria. Los jueces excepcionalmente podrían juzgar acerca del contenido de una decisión discrecional, aunque si de su arbitrariedad. Pero esto es propio del control de los actos administrativos o, incluso, de otro tipo de reglamentos administrativos, pero no puede aplicarse a estos tan singulares a los que la Constitución les otorgó un sistema de control especial por parte del Poder Legislativo.

Efectivamente, al sancionar un reglamento o decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo asume la competencia material que la Constitución le otorga al Congreso, regulando materias que corresponden sean tratadas por ley formal por expresa disposición constitucional. Lo expuesto no significa que la sanción de un decreto de necesidad y urgencia exprese una actuación irregular del Ejecutivo, en la medida que, bajo ciertas condiciones, tal actividad materialmente legislativa del Presidente de la Nación se encuentra autorizada por la propia Constitución en su art. 99, inc. 3.

195

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido desarrollando, en una jurisprudencia que todavía se encuentra en sus albores, la doctrina interpretativa del citado art. 99.3 CN. A partir de la misma—con inclusión importante del caso desarrollado: “Verrocchi, Ezio Daniel c. Poder Ejecutivo Nacional” (V.916. XXXII, del 19 de agosto de 1999)—, puede hacerse la siguiente síntesis:

Con una mayoría distinta, la Corte avanzó por el camino contrario a “Rodríguez”. En el considerando 9 del fallo, luego de recordar la excepcionalidad de la facultad del Poder Ejecutivo, se precisa: “...Por tanto, para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes...”, y nosotros le agregaríamos que la cuestión tenga un interés general y no sectorial.

CAPITULO II.4

LA PROMULGACIÓN PARCIAL DE NORMAS Y EL VETO PARCIAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Veto parcial. — 3. Promulgación Parcial de Leyes. — a) Concepto y clases. b) Organos de control. — 4. Comisión Bicameral Permanente. — 5. Evolución Jurisprudencial. — 6. Comentario a Fallo: Caso “Famyl S.A.”. a) Antecedentes fácticos y jurídicos. b) Pretensión de la parte actora. c) Objeciones planteada por la accionada. d) Voto de la mayoría. e) Glosa doctrinaria. — 7. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN (1)

Según Montesquieu, la división de poderes no es un sistema para gobernar mejor, sino la respuesta necesaria a la enseñanza histórica, en el sentido de que todo poder concentrado es poder tiránico. Que para detener la tiranía hay que dividir al poder político en su ejercicio. La visión que tiene Montesquieu en la primer mitad del siglo XVIII de las libertades en Gran Bretaña, frente a la contrapartida del absolutismo y concentración de poderes en su Francia, además del despotismo del resto de Europa continental, le lleva a enunciar que uno de los pilares básicos para garantizar la libertad individual, a través de la división en el ejercicio del poder político, reside en que los poderes constituidos, cada uno de ellos, tenga una función esencial, que no debe ser compartida, sino en márgenes mínimos, con los otros poderes.

Es de suma importancia entonces, la formación y sanción de las leyes, para promover el bienestar general. El proceso legislativo está reglado por la Constitución Nacional en el Título I de su parte orgánica, Sección I, Capítulo V, denominado “De la formación y sanción de las leyes”.

Consta de tres etapas claramente diferenciadas: formulación del proyecto (etapa de iniciativa), discusión y sanción (etapa constitutiva), y promulgación y publicación (etapa de eficacia).

(1) SABSAY, DANIEL—Director—, y coautores, coordinado por MARANIELLO PATRICIO y otra: *Análisis jurisprudencial en Derecho constitucional*, Capítulo XXII “Aspectos limitativos del veto parcial y la promulgación parcial de normas por parte del P.E.”, coautor MARANIELLO, PATRICIO, Buenos Aires, 2002.

Es dable destacar que ni la etapa de iniciativa ni la de eficacia importan ejercicio de la función legislativa, aunque puede ocurrir que el proyecto de ley surja del propio seno legislativo. Sin embargo, en este caso no será tomado como una facultad exclusiva de éste, dado que también se encuentran habilitado constitucionalmente para ello el Poder Ejecutivo Nacional —art. 77 de la CN— y el pueblo, a través de la iniciativa popular —art. 39 de la CN—. En consecuencia, la facultad legislativa sólo radica en la fase constitutiva que está a cargo en forma exclusiva y excluyente del Congreso Nacional.

Como ya adelantamos, el Poder Ejecutivo interviene, por mandato constitucional y en circunstancias normales, en dos de las tres etapas del proceso de formación de las leyes, en la de iniciativa, promulgación y publicación.

En la de *iniciativa*, dispone de la facultad de remitir, a cualquiera de las cámaras, aquellos proyectos de ley que considere necesarios para llevar adelante su plan de gobierno. Es en esta etapa donde se le reconoce al presidente una participación co-legislativa, aunque este término se puede prestar a confusión.

En lo atinente a la *eficacia*, su intervención constituye un requisito esencial para que el proyecto sancionado por el Congreso adquiera vigencia de ley y obligatoriedad, mediante la promulgación y posterior publicación de la norma legal. En esta etapa también se encuentra la función de "control", donde se encuentra el veto y se le reconoce "naturaleza ejecutiva o política".

Montesquieu llamaría a esta atribución "facultad de estatuir", que comprende no sólo el derecho de legislar por sí mismo, sino el de corregir lo que haya ordenado otro.

De todo ello, se desprendería que existe dentro del control una posición co-legislativa o "participativa necesaria" por parte del Poder Ejecutivo; pero no legislativa por lo ya aludido precedentemente, encontrándose prohibido la emisión de disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, aunque esta limitación se mantiene a lo largo de la Ley Fundamental, la misma no resulta absoluta, sino relativa a ciertas circunstancias excepcionales, donde luego de la última reforma constitucional del año 1994, se han incorporado tres institutos de acrecentamiento de dicha potestad y estos son: a) *delegación legislativa* —art. 76 de la CN—, b) *promulgación parcial* —art. 80 de la CN— y, c) *decretos de necesidad y urgencia* —art. 99 inc. 3—.

Empero, en la promulgación parcial de leyes —que ha merecido la crítica prácticamente unánime de la doctrina por afectar la clásica división de poderes propia del sistema republicano de gobierno— se deberá analizar, de distinta forma que los demás institutos, ya que, encierra la particularidad de que su utilización depende del uso indispensable de dos elementos constitucionales para su funcionabilidad y estos son el uso el "veto", pero sólo en su modo "parcial" ya que si se efectúa en forma "total" el proyecto de ley deberá girarse indefectiblemente al Congreso sin posibilidad de emitir normativa alguna, y el otro elemento es la denominada "*promulgación parcial de leyes*" bajo ciertos requisitos.

Como se podrá notar, esta facultad resulta una herramienta de vital importancia, cuyo tratamiento y análisis demostrarán los puntos más vulnerables y equívocos que revisten los mismos a través de las distintas opiniones doctrinales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

2. VETO PARCIAL (2)

El Veto, primer elemento de este instituto que proviene del latín 'prohibir', es una prerrogativa por parte de alguno de los poderes del Estado (normalmente el Poder Ejecutivo, bien el presidente del gobierno, bien el de la República en los regímenes presidencialistas, pero también las Cámaras altas de algunos parlamentos).

El término veto tiene también una acepción referida al Derecho internacional, que se manifiesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cada uno de sus cinco miembros permanentes (Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Estados Unidos) tiene poder de veto en todos los asuntos fundamentales.

El monarca de Gran Bretaña tiene poder de veto absoluto desde hace mucho tiempo, pero esta prerrogativa no ha sido ejercida desde 1708. El presidente de Estados Unidos puede vetar un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso, aunque este veto puede ser anulado si en el Congreso se obtiene una mayoría de dos tercios en la votación. El derecho al veto concedido a Luis XVI de Francia en la Constitución de 1790, redactada durante la Revolución Francesa, le valió a él y a María Antonieta de Austria los apodos de 'Monsieur Vêto' (Señor Veto) y 'Madame Vêto' (Señora Veto), después de que aquél vetara la legislación de la nueva Asamblea.

En España, como queda recogido en el artículo 90 de la Constitución, corresponde al Senado ejercer el derecho de veto, por mayoría absoluta, respecto a los proyectos de ley remitidos por el Congreso de los Diputados, en un plazo de dos meses, de seguir el procedimiento habitual, o de veinte días, en los proyectos tramitados por vía de urgencia. No obstante, este derecho de veto no es absoluto frente a la ratificación del Congreso, por mayoría absoluta, e incluso por mayoría simple si dicha ratificación se verifica al cabo de dos meses desde la interposición del veto por el Senado.

En nuestro país, la palabra "veto" no es usada por la Constitución Nacional, pero si es utilizada habitualmente en el lenguaje constitucional. El veto es la herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo para aprobar o desechar total o parcialmente un proyecto de ley haciendo funcionar de esta manera la actividad colegislativa que la Carta Magna le reconoce.

El veto como mecanismo de control institucional, puede cobijar distintas motivaciones tanto políticas como jurídicas y dentro de las primeras también

(2) MARANIELLO, PATRICIO, "Alcances del veto parcial del Poder Ejecutivo en el tributo a la medicina prepa...", LA LEY, del 26/5/1999.

aquellas que se identifican con la política agonal y su consecuente bloqueo de la voluntad legislativa. A pesar de esto último, el veto "no es peligroso para las instituciones, ni debe ser mirado como un arma extraordinaria en manos del Poder Ejecutivo".

A lo largo de nuestra Constitución Nacional, se visualizan dos tipos de veto, el veto total y el parcial. Este último ha adquirido una importancia aún más significativa, ya que no solo le permite al Poder Ejecutivo rechazar en forma parcial un proyecto de ley proveniente del Congreso, sino además, le puede dar nacimiento a la parte no vetada, promulgándola parcialmente.

3. PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES

En lo que respecta a la viabilidad de la promulgación parcial, antes de su introducción en el año 1994, no existía una uniformidad de criterios en la doctrina constitucional. Algunos autores, tales como González Calderón, Linares Quintana y Bidart Campos, la habían reputado inconstitucional, porque veían en esa incorporación constitucional un acrecentamiento de las facultades presidenciales sin el debido control; en cambio para Bielsa, Romero, Bidegain, Ramella y Vanossi, entre otros, la Constitución no se opone a la promulgación parcial, siempre que la supresión de la parte vetada no altere la esencia y finalidad del proyecto de ley aprobado por el Congreso, según la apreciación en cada caso concreto realice el órgano judicial.

a) Concepto y clases

A la promulgación, la podemos definir como el acto formal por el cual el Poder Ejecutivo aprueba y dispone publicar un proyecto de ley, otorgándole eficacia al mismo.

El art. 78 de la Constitución Nacional establece que todo proyecto de ley que obtenga sanción definitiva en el Parlamento, debe ser sometido al examen del Poder Ejecutivo. Este tiene, en principio, dos opciones:

- a) aprobarlo y promulgarlo, u
- b) observarlo y devolverlo al Congreso.

Cuando el Poder Ejecutivo *aprueba* el proyecto sancionado por el Congreso, éste se convierte en ley.

En lo atinente a la *promulgación*, debemos distinguirla en dos clases:

- *Expresa*, cuando el titular del Poder Ejecutivo, emite un decreto de promulgación (art. 78, CN).
- *Tácita*, cuando el Poder Ejecutivo no aprueba expresamente el proyecto sancionado, pero tampoco lo devuelve observado al Congreso dentro del término de diez días hábiles (art. 80, CN).

En cualquiera de los dos casos, la voluntad del órgano ejecutivo concurre a conferir eficacia al proyecto de ley, tal como adelantásemos.

La segunda alternativa que tiene el Poder Ejecutivo es la *observación* del proyecto en su totalidad o en alguna de sus partes. Se trata de una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, que le permite manifestar su disconformidad con la sanción del proyecto. Es un acto de naturaleza política que en el lenguaje constitucional se conoce como expresamos en el punto anterior, con el nombre de "veto", aunque la Constitución no utilice tal palabra.

El veto puede ser:

- a) *Absoluto*: Cuando la negativa del Poder Ejecutivo tiene el efecto de suspender el proyecto sancionado hasta el próximo período legislativo. En los Estados Unidos, la Constitución faculta al Presidente a efectuar lo que se ha denominado "veto de bolsillo" (*pocket veto*).
- b) *Limitado*: En este caso, el Presidente devuelve el proyecto en trámite a las cámaras legislativas para que lo examinen nuevamente, exponiendo los argumentos por los cuales se niega a promulgarlo. Tiene el carácter de un recurso de reconsideración ante la propia Legislatura. Este último es el que contempla nuestra Constitución Nacional.

A partir de la reforma constitucional de 1994, el trámite a seguir ante un veto parcial está expresamente legislado en el art. 80 de la Carta Magna, que establece que los proyectos vetados parcialmente por el Poder Ejecutivo no pueden ser promulgados en la parte restante. No obstante, el mismo artículo contempla una excepción a la norma, al permitir la promulgación de las partes no observadas, cuando *posean autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso*. Por último, la norma constitucional dispone que la promulgación parcial de lo no vetada tenga el mismo trámite que los decretos dictados por razones de necesidad y urgencia.

La historia constitucional argentina, hasta fines del siglo pasado, registra pocos ejemplos de veto parcial y promulgación parcial de las leyes, y la mayoría, corresponden a leyes de presupuesto. Con posterioridad, adquirieron mayor asiduidad, contemplándose en algunos casos su inconstitucionalidad, pero no en lo atinente a su proceso adjetivo, sino en su aspecto sustantivo.

b) Organos de control

El interrogante del órgano contralor —dado que la Constitución Nacional es ambigua al respecto— apunta hacia quién es el encargado de decidir si la parte no vetada que se promulga parcialmente tiene o no autonomía normativa y si altera o no el espíritu y la unidad de la ley. Dejando sentado que el mentado control sólo se refiere al que se podrá efectuar con posterioridad a su promulgación, ya que en forma previa no participa ningún otro órgano, dado que es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual desfavorece el equilibrio que debe existir entre los poderes en un sistema democrático.

198